

社群媒體不實訊息之治理^{*} ——以個資保護模式為選項

翁逸泓^{**}

摘要

本文探索藉由社群媒體而以個資投放不實訊息之治理可能論理與架構建議。我國於實踐民主程序中無論是選舉當下或選後所受到之內在與外來不實訊息擾動之威脅，不實訊息之攻擊未曾因為大型選舉結束而減緩，且其傳播係為跨社群平臺方式，除造成個資權利受影響，也大幅降低社會成員間彼此之信任關係。

本文以歐盟相關立法、研究以及實踐策略做為借鏡對象，認為如果要尋得威脅民主社會之癥結，則與其僅只聚焦在「惡」、「假」與「害」等構成要件爭點處理，毋寧應把焦點也放在對於資訊傳述過程，尤其是個資蒐集階段之有效辨識與積極對待。在分析以個資保護模式作為不實訊息管制之切入點與言論自由保障之關係後，本文認為在法制上需特別注意對於個資控管者與資料中介者之課責，而成立一個真正具對應資源與能量的獨立專責機關，才是目前臺灣能解決相關問題的起點。

* 投稿日：2020年2月19日；接受刊登日：2021年7月5日。〔責任校對：莊佩芬〕。

本文為作者執行科技部研究計畫（MOST 108-2410-H-128-011-）之研究成果。作者衷心地感謝諸位審稿人及出版委員會委員之具體評論、建議與提點，這些寶貴的意見對本文以及對於作者本身都有極大幫助與鼓勵，也謝謝期刊編輯對作者莫大之容忍，惟文責當由作者自負。

** 世新大學法律學院副教授。

穩定網址：<http://publication.ias.sinica.edu.tw/12021022.pdf>。



關鍵詞：個資保護、GDPR、不實訊息、假新聞、言論自由。

目次

壹、前言	肆、實際踐行：界限與策略
貳、不實訊息與社群媒體	一、言論自由作為民主基石的要素
一、資訊失序：作假與放屁	二、個資保護與言論自由的緊張關係
二、失序潰堤：社群媒體即是不實訊息傳遞過程之溫床	三、治理的建議
參、個資保護作為切入點：先期階段的介入	伍、結論

壹、前言

本文所討論之主題為探索個人資料保護作為治理社群媒體此種以資料驅動（data-driven）類型之不實訊息／資訊（disinformation）的論理基礎，以及建議的執行策略。

2018年堪稱是臺灣「假新聞」¹開始令人感覺到嚴重肆虐的一年。例如，在2018年6月間，社群媒體上謠傳高雄旗山香蕉滯銷，

1 基於「假新聞（fake news）」這個詞彙在定義與內涵上充滿爭議，例如Edson C. Tandoc, Jr.教授將其分類為包括新聞嘲諷、戲謔仿作、虛構新聞、圖像操弄、公關廣告與政治宣傳廣告等六大類型者，其詳細中文介紹參：黃銘輝，從言論自由的觀點初論網路假新聞的管制，收於：彭芸、葉志良編，「匯流、治理、通傳會」論文集，頁114-116（2018年）。其他的定義請參：黃銘輝，假新聞、社群媒體與網路時代的言論自由，月旦法學雜誌，292期，頁8-11（2019年）。對此等定義，歐盟甚至將該詞彙「套用在特定意識形態的傳播者身上，可能加深對立，或成為打擊政治對手的工具」。本文主要重點聚焦在不實訊息（disinformation）上，且歐盟在其相關報告上以及我國正式官方文件與用語上漸統一使用「不實訊息」一詞，故本文均使用該詞彙。Google如何打擊不實資訊，Google，2019年2月，頁2，<https://drive.google.com/file/d/19Xy9He7qAMEhsIlrY8jU3THIYuXkjpY9/view>（最後瀏覽日：2021年4月24日）。另外，關於歐盟

甚至有造謠者附上照片。當時的行政院農委會雖然即刻澄清該照片是11年前的照片，但是該則訊息早已坊間滿盈²。為此，行政院會於2018年12月13日基於「近年來部分人士及境外勢力濫用言論自由，透過新興網路科技與社群媒體等，刻意捏造及散布假訊息，企圖干擾民眾生活與社會秩序，嚴重傷害社會安定，為防杜散播假訊息造成危害」之理由³，而通過其轄下包括內政部、農委會、衛福部、原能會，以及作為獨立機關的通傳會分別擬具之《災害防救法》第41條修正草案、《糧食管理法》第15條之1、第18條之3修正草案、《農產品市場交易法》第6條、第35條修正草案、《傳染病防治法》部分條文修正草案、《食品安全衛生管理法》第46條之1修正草案等修正現行有關散播謠言或不實訊息罪的相關罰則，並擬具《核子事故緊急應變法》第31條之1修正草案及《廣播電視法》部分條文修正草案增訂廣電業者自律規範機制、事實查證規定及其罰則等7項法案，函請立法院審議。

而這個「假新聞」關鍵字對臺灣整體社會、法律制度與實務的影響，也從2018年的選舉一路延燒至2020年大選，甚至於2020年最重大的嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）國際公共衛生事件，也仍圍繞著這個爭議。不過這個爭議涉及了至關重要的言論自由之侵害防免問題，尤其是就發出言論的權利主體（speaker）來說，言論／表意與新聞之自由係為憲法上保障之基本權利，相對地就接收言

基礎報告，參：European Commission, *Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Tackling Online Disinformation: A European Approach*, COM (2018) 236 final (Apr. 26, 2018), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0236&from=EN>.

- 2 劉怡馨，香蕉假新聞瘋傳，農委會痛批散播謠言，蕉價雪上加霜，揚言提告，上下游News&Market，2018年6月7日，<https://www.newsmarket.com.tw/blog/110005/>（最後瀏覽日：2021年4月24日）。
- 3 行政院，行政院會通過「災害防救法」第41條修正草案等7案，2018年12月13日，<https://www.ey.gov.tw/Page/9277F759E41CCD91/27188d0c-a138-4b1f-a292-340f18824a42>（最後瀏覽日：2021年4月24日）。

論資訊者／閱聽人（receiver）言，接近使用傳播媒體，亦為大法官所肯允之權利保障態樣⁴。究其所以，乃係大法官以及國際人權保障機構等，均肯認民主制度之最重要基石厥為言論自由⁵。也因此對於不實訊息的諸多爭議，多數文獻將關懷切入點聚焦在言論自由限制與審查之兩難問題⁶。以此面向切入之觀點而就大眾傳播與媒體法等領域之分析研究，例如對純屬虛構資訊、品質不好的真實訊息以及假扮新聞的廣告等不同類型之言論定性⁷，或牽涉到對於仇恨言論、歧視言論及不受歡迎言論之法律適用操作標準等概念⁸。而以民主法之角度思考，亦有在對民主防衛的焦慮當中，基於該等管制是否能通過違憲審查之疑慮，而考量該等防衛管制措施可能反而箝制少數群體或反對者之自由與基本權利的風險等。

4 司法院釋字第364號解釋理由書：「至學理上所謂『接近使用傳播媒體』之權利（the right of access to the media），乃指一般民眾得依一定條件，要求傳播媒體提供版面或時間，許其行使表達意見之權利而言，以促進媒體報導或評論之確實、公正……惟允許民眾『接近使用傳播媒體』，就媒體本身言，係對其取材及編輯之限制。」本解釋認為「接近使用傳播媒體」與「媒體的編輯自由」具有基本權衝突的問題。「如無條件強制傳播媒體接受民眾表達其反對意見之要求，無異剝奪媒體之編輯自由，而造成傳播媒體在報導上瞻前顧後，畏縮妥協之結果，反足影響其確實、公正報導與評論之功能。是故民眾『接近使用傳播媒體』應在兼顧媒體編輯自由之原則下，予以尊重。」

5 司法院釋字第445號解釋，段1；司法院釋字第756號解釋理由書，段4；另參翁燕菁，言論的自由與責任：自歐洲人權法院近年爭議裁判反思，台灣法學雜誌，363期，頁6（2019年）。

6 翁燕菁（註5），頁7；參沈伯洋，媒體意識轉換以及言論管制，月旦刑事法評論，9期，頁79-88（2018年）；鍾禎，論國家對於假消息之管制模式及其規範分析——國際宣言與比較法的觀點，憲政時代，43卷3期，頁425-476（2018年）。See also TOM GINSBURG & AZIZ Z. HUQ, HOW TO SAVE A CONSTITUTIONAL DEMOCRACY (2018); STEVEN LEVITSKY & DANIEL ZIBLATT, HOW DEMOCRACIES DIE (2018); YASCHA MOUNK, THE PEOPLE VS. DEMOCRACY: WHY OUR FREEDOM IS IN DANGER AND HOW TO SAVE IT (2018)，轉引自蘇彥圖，當代自由民主的焦慮，中研院訊，1694期，頁13-16（2019年）。

7 參何吉森，假新聞之監理與治理探討，傳播研究與實踐，8卷2期，頁1-41（2018年）。

8 參見蘇慧婕，第三帝國陰影下的言論自由保障：論德國聯邦憲法法院在政治極右言論案件中的立場演變，臺大法學論叢，45卷2期，頁396-453（2016年）。

相較前述文獻及我國行政部門對於不實訊息的管制與討論的出發點，本文之研究將由個資保護之角度切入，特別針對不實訊息與虛假傳述等之投放源頭的個資蒐集、處理與利用分析其法律上爭議，以及可能發生的與其他基本權利與自由競合及衡平等議題加以處理⁹。本文之所以採取不同出發點與策略之思維方式，是因為不實訊息對於人權的直接影響不僅只在言論與表意自由權面向，亦對於隱私權及個資保護諸權利具有衝擊與侵害風險¹⁰。不過需要特別說明的是，在此所謂「從不同的角度」出發，本文在論理上並不認為應當捨棄言論自由在不實訊息管制模式中所應扮演之角色，而是強調個資保護之管制方法在類型上與有效性上，可以與言論自由相輔相成，強化並補充管制效果。

雖然目前在我國似乎較少有從此角度來解析不實訊息處理的相關討論，但是從國際上比較法制與實務之面向來看，以個資保護之角度出發來管制不實訊息並非空言。然而，在我國實務上行政部門對「假新聞」的立即反應並未如同英國調查劍橋分析案（Cambridge Analytica）一般，由個人資料保護法（下稱個資法）作為出發點，而使相關獨立專責機關作為行政調查之開端：於2018年12月初英國資訊委員（Information Commissioner）在英國國會發表其調查報告指出透過對於Facebook往來電子郵件之釐清，發現其雖然未曾「直接」出售或提供使用者個資給特定大型企業，但卻經常「利用」使用者之個資銷售廣告，同時也阻斷競爭對手與Facebook之連結¹¹。

9 至於研究限制部分，因為關於不實訊息之法律層面涉及議題多元，本文僅將焦點集中於關於不實訊息投放之個資保護治理問題。

10 Judit Bayer et al., *Disinformation and Propaganda — Impact on the Functioning of the Rule of Law in the EU and Its Member States*, at 73, HEC Paris Research Paper No. LAW-2019-1341 (Feb. 2019), [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608864/IPOL_STU\(2019\)608864_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608864/IPOL_STU(2019)608864_EN.pdf).

11 Damian Collins, *Summary of Key Issues from the Six4Three Files*, <https://www.parliament.uk/documents/commons-committees/culture-media-and-sport/Note-by-Chair-and-selected-documents-ordered-from-Six4Three.pdf> (last visited Apr. 24, 2021).

雖然Facebook隨即澄清並未「出售」使用者之個資¹²，然輿論反應上並未接受該等說詞¹³，不惟英國，美國紐約時報亦報導揭露此事，更進一步指出該等接受Facebook個資之企業包括Microsoft、Amazon.com與Netflix等；而匈牙利更是對於Facebook在其廣告上宣稱其係完全免費，而掩飾其廣告收入係利用消費者個資之事實，予以巨額罰款¹⁴。

為達成研究目的，本文研究之問題依序有三，而這三個問題也形成本文各章節內容之架構順序：(1)不實訊息於社群媒體之問題辨識；(2)以個資保護理論與實務作為不實訊息管制之切入點，並分析其與言論自由保障之相互競合關係；以及(3)可能的相應對策。

在第一個研究問題的階段，本文將首先對於不實訊息的定義、內涵、類型以及究責策略等，加以辨識。在分歧的概念與定義中，本文認為應如同歐盟之定義，擴張地包含扭曲認知與虛假傳述等類型。而在現今社群媒體上各類訊息傳播發達活躍時代，該等平臺乃係最需要與最值得投入治理資源與成本之處。也因此本文將社群媒體上傳播不實訊息之過程，尤其聚焦於對於個資之蒐集時可能違反個資保護基本原則而投放問題，作為研究之主要焦點。至此，本文嘗試建構以個資保護作為治理模式之可能性，並在其後轉向實際之操作策略，在將焦點放在資訊傳播過程之管制模式重點與相對應之審查標準，以釐清管制之範圍界限何在之後，本文試圖提出包括在個資處理之早期階段即給予蒐集之指引，以及設立一個獨立專責的

12 Facebook, *Response to Six4Three Documents*, META (Dec. 5, 2018), <https://newsroom.fb.com/news/2018/12/response-to-six4three-documents/>.

13 Siva Vaidhyanathan, *Violating Our Privacy Is in Facebook's DNA*, THE GUARDIAN (Dec. 20, 2018), https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/dec/20/facebook-violating-privacy-mark-zuckerberg?CMP=tw_t_gu&fbclid=IwAR27v2vNawbDnFth_cmvmxsfHc0vfFofX_Fx9t6oI2VTcKp3Wn6lP8oQnck.

14 Marton Eder, *Facebook Gets \$4m Fine from Hungary for Claim Services Are Free*, BLOOMBERG (Dec. 06, 2019), <https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-06/facebook-gets-4m-fine-from-hungary-for-claim-services-are-free>.

資訊保護機關等策略，作為本文提供實務參考之價值。

又，基於個資保護之概念、體系建構以及具體實踐等，都以歐洲較具有國際上影響力，且我國個資法係移植自歐盟個資保護相關法制，因此本文主要以歐洲相關立法、研究以及實踐策略做為借鏡對象。在研究範圍方面，因為本文主要參考之歐洲個資保護之模式對社群媒體不實訊息之管制範圍在策略上聚焦在政治公共利益面向，本文也因此將論述範圍集中焦點於此，而不及於有涉公平交易法之誤導性與比較廣告類型等。再者，為避免本文研究爭點過度發散而導致難以聚焦，關於包括媒體平臺責任、透過演算法散布不實訊息之問題等，均非本文討論範圍，合先敘明。

貳、不實訊息與社群媒體

一、資訊失序：作假與放屁¹⁵

倘意欲以法律論理之方式解構關於「不實訊息」之爭議與其治理問題，則首要任務即在辨識「不實訊息」之定義與概念內涵。通俗的「假新聞」這個詞彙無論就定義上或是內涵上而言，概念都相當地不精準，也無法體現其當代性之意義¹⁶。相對地如以行政院針

¹⁵ 基於Harry G. Frankfurt所著作ON BULLSHIT一書中文授權版之翻譯書名為「放屁」，雖難免不雅，但基於尊重譯者及學術倫理，因此本文行文遵照原譯者翻譯。參：Harry G. Frankfurt著，南方朔譯，放屁！：名利雙收的捷徑（2006年）。另外，以Bullshit代稱虛假傳述概念者，也在Yochai Benkler等人之著作中出現。參：YOCHAI BENKLER ET AL., NETWORK PROPAGANDA: MANIPULATION, DISINFORMATION, AND RADICALIZATION IN AMERICAN POLITICS 24, 32-33 (2018).

¹⁶ 這個詞彙近來成為熱門話題乃是伊始於2016年時Craig Silverman與Lawrence Alexander在Buzzfeed揭露有百餘個支持川普的網站提供美國新聞與政治分析，但其實這些網站都是由馬其頓所發出，且多為不實的「假新聞」。See Craig Silverman & Lawrence Alexander, *How Teens in the Balkans Are Duping Trump Supporters with Fake News*, BUZZFEED NEWS (Nov. 4, 2016), <https://www.buzzfeednews.com/article/craigsilverman/how-teens-in-the-balkans-are-duping-trump-supporters-with-fake-news>.

對「不實訊息」這個概念所發布之認定標準來看，其定義包含要有「惡」的故意或意圖、「假」的捏造或虛構行為，以及造成危害或損害的「害」等三個構成要件，針對「明知為假訊息仍故意散播，因而造成公眾畏懼和恐慌危害」情況，由法制面進行補強，以遏止「出於惡意、虛偽假造、造成危害」之假訊息，降低其對國家社會、公共利益所生負面影響¹⁷，也因此當前公務部門在面對不實訊息時均以此作為管制線索，而多有事後「嚴懲」之作為¹⁸。

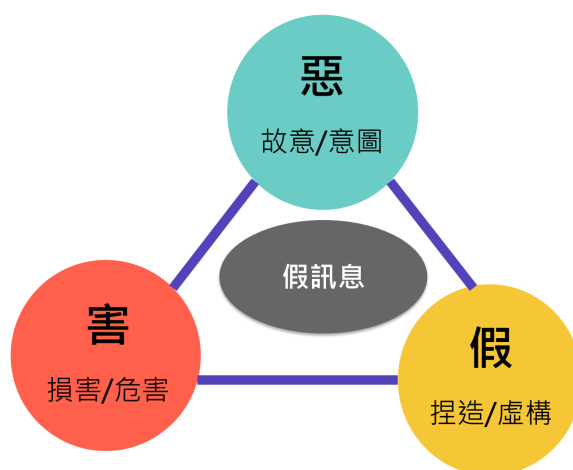


圖1 不實訊息構成要件關係圖

資料來源：行政院，防制假訊息危害因應作為，2018年12月13日，<https://www.ey.gov.tw/Page/448DE008087A1971/c38a3843-aaf7-45dd-aa4a-91f913c91559>（最後瀏覽日：2021年4月24日）。

buzzfeednews.com/article/craigsilverman/how-macedonia-became-a-global-hub-for-pro-trump-misinfo.

¹⁷ 行政院，防制假訊息危害因應作為，2018年12月13日，<https://www.ey.gov.tw/Page/448DE008087A1971/c38a3843-aaf7-45dd-aa4a-91f913c91559>（最後瀏覽日：2021年4月24日）。

¹⁸ 例如以社會秩序維護法作為處罰之依據，然而就該法本身言，在我國公法領域非必沒有對於其適法性之討論空間。

行政院對此三要素相互之間的關係，乃以上圖表示，更精細地來說，在行政院的相關專案報告中，將其定義為¹⁹：

行為人將自己或他人捏造、扭曲、篡改或虛構全部或部分可證明為不實的訊息（包括資訊、消息、資料、數據、廣告、報導、民調、事件等各種媒介形式或內容）。

故意甚至是惡意地藉由媒體、網路或以其他使公眾得知之方法，以口語、文字或影音的形式傳播或散布於眾，引人陷入錯誤，甚至因而造成公眾或損害個人，即具有法律問責的必要性。

然而，在當前資訊超載（information overload）²⁰狀態下，面對因為不實訊息之散布所導致各類型資訊失序（information disorder）的狀況²¹，前述行政院所下之定義是否能完整地包括並處理不實訊息問題之癥結，不無疑問。質言之，不實訊息的「惡」、

19 參外交國防法務處，防制假訊息危害專案報告，行政院，2018年12月13日，頁5，<https://www.ey.gov.tw/Page/448DE008087A1971/c38a3843-aaf7-45dd-aa4a-91f913c91559>（最後瀏覽日：2021年4月24日）。（粗體強調為原文所加，底線強調為本文作者所加。）

20 Massimo Flore et al., *Understanding Citizens' Vulnerabilities to Disinformation and Data-Driven Propaganda*, at 14-17, EUR 29741 EN (2019), http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116009/understanding_citizens_vulnerabilities_to_disinformation.pdf (last visited Apr. 24, 2021).

21 需注意者，在歐洲理事會關於資訊失序的報告中，「資訊失序」這個概念包含了三個類型的失序狀態：

錯誤資訊（Mis-information）是指分享虛假資訊，但未造成傷害；不實訊息（Dis-information）是指故意分享虛假資訊，並造成傷害；惡意資訊（Mal-information）是指共享真實資訊卻造成傷害，通常是通過轉移旨在保密的資訊進入公共領域。

在此三類型中關於惡意資訊之類型，其重點在於移轉私人秘密資訊至公共領域，與本文在不實訊息類型中所論述的扭曲認知與虛假傳述類型，在內涵上有所不同，併此說明。Claire Wardle & Hossein Derakhshan, *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making*, at 20, Council of Europe Report DGI(2017)09 (Sept. 27, 2017), <https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-research/168076277c>.

「假」、「害」三個構成要件都必須要同時滿足的情況下，是否包含之類型不夠完整，而無法有效地處理當代關於「不實訊息」爭議？而即便符合了不實訊息的定義，是否又均需要予以無差別地耗費國家資源與成本加以管制或處罰該傳播或散布不實訊息之行為？

如果從「害」的觀點作為基準點加以分析，則未有「惡」的錯誤資訊（misinformation）流傳，亦可能導致與不實訊息一樣之實害結果或升高風險。另外，傳遞之資訊內容雖是全部或部分真實的事實本身而未有「假」，但倘若還伴隨著具引導性之意見陳述或選擇性資訊陳列，亦有扭曲認知（distorted perceptions）或虛假傳述（fake narratives）²²等類型，一樣地會造成民主威脅與失序，而後者可能為患之嚴重性，則可能更甚於行政院版本所定義之不實訊息。

所謂**扭曲認知**係表意人陳列之資訊**並無不實**，但是僅將**正確**資訊予以部分提供；又或在陳列對比資訊時，刻意放大或縮小掩飾部分資訊，而通常以負面的方式來扭曲人們對現實或認知觀點上的感知。最常出現的例子就是在新聞標題上刻意擷取其中一個面向，並予以誇大，但事實上在新聞本文中還是有將資訊正反並陳，以規避事實查證或其他新聞倫理之責任²³。這種類型在臺灣也經常被民眾稱為「標題殺人」。在概念上，也有學者將此扭曲認知之定義內涵納入不實訊息範疇，例如學者Yochai Benkler等人將不實訊息定義為「傳播明確的虛假或誤導性資訊（dissemination of explicitly false or misleading information）」，令其同時包括「黑色和灰色」之資訊傳播：黑色指的是來源或內容純屬虛假的宣傳，而灰色指的是資訊本身為正確，但其來源和內容被更巧妙地掩蓋和操縱以顯示為其他形式的宣傳²⁴。

22 PAUL BERNAL, THE INTERNET, WARTS AND ALL: FREE SPEECH, PRIVACY AND TRUTH 234-39 (2018). See also Paul Bernal, *Fakebook: Why Facebook Makes the Fake News Problem Inevitable*, 69 N. IRELAND LEGAL Q. 513, 515-16 (2018).

23 Flore et al., *supra* note 20, at 2-6.

24 BENKLER ET AL., *supra* note 15, at 24.

另一方面，所謂**虛假傳述**係指行為人對於無論正確與否之事實，在主觀上並不那麼在乎對錯（所以可能發生未必故意或是有認識的過失），或甚至真摯而合理地認為並無錯誤，而在客觀上加以指謫或傳述意見或評論²⁵。在此，即必須清楚地區分行政院版本不實訊息之定義與虛假傳述之差異：前者所指的「假」係就**事實或資訊本身**的「假」；後者則是關於**某真正事實之意見評論或評價**。在言論自由以及誹謗概念之範疇中，如果基於正確之事實，則可能不被課責；但即便如此，仍可能透過一定程度虛假之隱喻或暗喻之方式，對他人或公共利益造成損害或負面之道德情感上評價²⁶。例如，近來歐洲難民人數增加是正確事實，但是難民的到來「可能」會使得各國健康照護體系產生不利益，則不一定是錯誤的推測性意見評價。更何況，在此所謂的「不利益」，可能指的是「傷害了國民感情」，而此種情感之意見表達經過傳述，通常隱喻著雖然表意人沒說出口，但是接收人會理解為此難民接納的真正事實會產生對原本納稅人的不公平之對待（因為難民之前並未納稅），而造成原國民對難民與接納該等難民政府之負面道德情感評價，進而使得執政黨面臨選舉與治理上之困境²⁷。在此，此種讓人覺得不公平的情感，並無法加以驗證，則Harry G. Frankfurt指出該等虛假傳述可能比謊言等不實訊息，造成更嚴重之損害結果，究其原因，在情感上聽到想聽的話終究比誠實的理性分析來得更為動聽，不過這些動聽的「屁話（bullshit）」，卻可能因為將社會審議對話之重心移轉而使得討論失焦，使得對話各方對於彼此之信任感降低，而重大地妨害了民主²⁸。

綜上，如果仍以行政院版本定義來檢視，則在關於扭曲認知類型中，對於「假」之構成要件，在未有「全部或部分可證明為不實

25 *Id.*

26 BERNAL, *supra* note 22, at 235-36.

27 BERNAL, *supra* note 22, at 236.

28 See HARRY G. FRANKFURT, ON BULLSHIT (2005).

的訊息」的情況下，並無法符合該要件，所以雖然可能會有更嚴重之實害結果，但似乎無法被行政院의 定義範圍所包括。而就「虛假傳述」之類型言，如果行為人主觀上係不在乎真假，當然有可能具有未必故意或有認識過失之情況，但也可能此等虛假傳述係發生於行為人主觀認為真實，甚至經過查證而傳述的情況，但無論如何因為該等傳述者係為意見、評論，而不是可驗證的事實，因此同樣地無法被行政院的定義範圍所包括。既然如此，我國相關法案之修正是否真的能夠對症下藥，不無疑問。

故而，本文認為行政院版本對於不實訊息的定義，有更精確並擴張化之必要：在行政院定義中，雖然也有「扭曲」作為行為態樣，但是其後（被扭曲的）客體仍須有假的成分，也就是「全部或部分可證明為不實的訊息」。相對地，歐盟執委會發布通告（communication）之「解決線上不實訊息：歐洲模式」²⁹、歐盟執委會高階專家團（High Level Expert Group）之報告「多元面向的不實訊息獨立報告」³⁰以及歐盟執委會通過，並由Facebook、Google、Twitter及YouTube等國際性大型搜尋引擎與社群媒體平臺簽署之「歐盟不實訊息實踐準則（EU Code of Practice on Disinformation）」³¹等文件則將不實訊息定義為「可驗證的錯誤或誤導性的訊息（verifiably false or misleading information）」。在此概念下尚有另兩個積極要件：(1)為了經濟利益而創造、表達和傳播不實訊息，或以不實訊息故意欺騙公眾；以及(2)可能造成公共危害，亦即意圖對民主政治和決策過程及公共利益（如對歐盟公民的健

²⁹ European Commission, *supra* note 1.

³⁰ European Commission, Directorate-General for Communication Networks, Content and Technology, *Final Report of the High Level Expert Group on Fake News and Online Disinformation* (Mar. 12, 2018), <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-level-expert-group-fake-news-and-online-disinformation>.

³¹ European Commission, *Code of Practice on Disinformation* (Sept. 26, 2018), <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation>.

康、環境或安全等）造成傷害。消極要件上，不實訊息的概念不包括誤導性的廣告³²、錯誤的報導、戲謔仿作，或明確為政黨趨向的新聞與評論等，並且不妨礙干擾既有之具拘束力的法律義務、自律廣告準則和誤導廣告的標準。由於歐盟不實訊息實踐準則就其主要適用範圍，係源自歐盟議會之政策研究報告，基於企圖將範圍限縮，因此依照是否具備歐盟整體「預期戰略效果（intended strategic effect）」以及是否具「政治性質之公共利益」分類，如同時具備前二者，則為究責範圍的不實訊息以及政治宣傳（propaganda）³³。而誤導性廣告如非政治性質，則被歸類為不在討論範圍內³⁴，因此可以發現歐盟為了精準地將管制與資訊治理成本有效應用，特別在策略上將資訊治理重心放在對於經濟與政治實害結果具有公共利益上的重大意義時，方加以特別對待處理。綜合以上分析，以歐盟賦予的相關概念言，則無論是扭曲認知或是虛假傳述，均滿足關於不實訊息定義之條件，但是必須與經濟效益或民主政治上具公共利益，才會再策略地投注成本與資源加以對抗。

總之，本文認為或許在管制上所應該聚焦之點不僅止對於訊息在客觀之「假」、主觀上「惡」，以及結果上「害」的處理，因為就前述討論中可以看見構成不實訊息的這三個要件分別有其存在需要，以及即便滿足要件也不一定需要毫無遺漏地以不合比例之資源

32 *Id.*

33 Bayer et al., *supra* note 10, at 17. 惟學者對此認為如果該等誤導性廣告具有政治上意涵，仍應在討論範圍之內。Patrick J. Birkinshaw, *Competition, Regulation, Public Service and the Market*, in *EUROPEAN PUBLIC LAW: THE ACHIEVEMENT AND THE BREXIT CHALLENGE*, ch. 12 (3d ed. 2020).

34 關於誤導與比較之廣告（advertising），歐盟以2006年誤導與比較性廣告指令（Directive 2006/114, of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 concerning misleading and comparative advertising, 2006 O.J. (L 376) 21-27）加以處理。需注意者，該指令所謂誤導與比較性廣告，指的是在比較內容的真實性層面，以區分為真實的比較廣告、真實但引人誤解的比較廣告、虛假的比較廣告等類型，而與其他之商品或服務廣告加以比較，在真實的比較廣告類型上，只要不侵害商標權，且不貶低被比較之商品或服務，則原則上係為合法。

與精力處理，又或早已可以以其他既有之法律手段（如公平交易法、政府資訊公開法，甚至個資法³⁵等）處理之情況。相對於把焦點僅僅集中在辨識何謂不實訊息的傳統脈絡上，本文認為之所以現今社群媒體時代視「假新聞／不實訊息」議題又成為熱門之焦點，原因不僅僅在於早已存在人類社會千年的「不實」訊息本身，而在於今日社群媒體透過大規模蒐集個資後處理而分享（sharing）的擴散本質，更利於該等不實訊息之傳播轉述而造成資訊之劇烈失序。以歐洲理事會相關報告為例，其特別點出在不實訊息的構成要件以外，基於創造不實訊息的內容、投放至網路媒體，以及利用個資與資訊科技加以擴散訊息的主體與動機均可能不同，而該等不實訊息一旦投放，就可以不同的動機無限地複製和重新投放擴散³⁶。

二、失序潰堤：社群媒體即是不實訊息傳遞過程之溫床

哈伯瑪斯（Jürgen Habermas）早在2006年就指出全世界數以百萬計的零散聊天室的興起，反而會導致龐大但政治集中的大眾零散地進入大量孤立的公眾論壇³⁷。其後Eli Pariser所稱「言論濾泡（filter bubbles）」，指例如Facebook等社群媒體之演算法先蒐集並且篩選出其認為使用者「想看」的動態貼文，接著該等訊息才會出現在使用者的動態，影響其使用者所看到的貼文與廣告³⁸。該等演算法計算基礎來自於大量蒐集使用者在Facebook甚至網路瀏覽器上先

35 須注意者，此間所傳遞之訊息／資訊中亦可能在內容上兼有個人資料而使得該種訊息之內容受到個資法之管制，例如個資法第9條第2項第2款的因為當事人自行公開或其他已合法公開之個人資料而使得其他人得例外地間接（再）利用個資而免為對於個資當事人告知。就此，本文認為本可以既有之法律規範處理。

36 Wardle & Derakhshan, *supra* note 21, at 22-23.

37 Jürgen Habermas, *Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Enjoy an Epistemic Dimension? The Impact of Normative Theory on Empirical Research*, 16 COMM. THEORY 411, 423 (2006).

38 See ELI PARISER, THE FILTER BUBBLE: HOW THE NEW PERSONALIZED WEB IS CHANGING WHAT WE READ AND HOW WE THINK 51-54 (2011).

前的線上行為，包括例如使用者訂閱的粉絲專頁、友人互動的頻率（按讚或其他表情、分享、留言）及是否點閱內容觀看與觀看黏著（engagement）長度等³⁹。

另一方面，由Cass R. Sunstein主張的「迴聲室效應（echoing chamber effect）」重點則在於使用者的個人選擇，這概念是指個體會選擇與自己立場相近的人成為好友，所以看到的朋友分享訊息跟自己立場相近；反之，個體也從臉書朋友中看到的立場來決定自己的立場。但是無論是哪一種情狀，當使用者從臉書好友分享訊息中所見的都會是相似立場時，該使用者便以為社會上的主流意見皆是如此⁴⁰。必須特別區分的是，Sunstein認為當權利主體只與志同道合之人對話時，除非在反對論證的語境之下對談，否則權利主體不會暴露其所反對的觀點和論據，也因此每個群體都會更加根深蒂固地固守自己的想法；而Pariser則認為權利主體選擇自我隔離是因為社群媒體平臺企業之演算法所致⁴¹。

社群媒體就其本質言，是積極地以演算法令其使用者創造並分享個人資料與資訊而強化彼此互動與對平臺之黏著度，而平臺的演算法需要個資分析（data analysis）、特徵剖析（profiling）以及利用個資精準投放（micro-targeting）⁴²以增加迴聲鞏固使用者，造成迴聲室效應以及言論濾泡⁴³。此時無論是言論濾泡或迴聲室，對於言

39 See Eytan Bakshy, Solomon Messing & Lada A. Adamic, *Exposure to Ideologically Diverse News and Opinion on Facebook*, 348 SCI. 1130, 1130-32 (2015). See also CASS R. SUNSTEIN, *REPUBLIC.COM 2.0* (2007).

40 See CASS R. SUNSTEIN, *ECHO CHAMBERS: BUSH V. GORE, IMPEACHMENT, AND BEYOND* (2001). 「迴聲室效應」通常在臺灣也經常被俗稱為「同溫層」。

41 BENKLER ET AL., *supra* note 15, at 290.

42 European Data Protection Board, *Guidelines 8/2020 on the Targeting of Social Media Users: Version 2.0*, at 7 (Apr. 13, 2021), https://edpb.europa.eu/system/files/2021-04/edpb_guidelines_082020_on_the_targeting_of_social_media_users_en.pdf.

43 學者有將此言論濾泡稱為「過濾罩效應者」，並且指出其不利民主多元社會之發展。參：翁清坤，大數據對於個人資料保護之挑戰與因應之道，東吳法律學報，31卷3期，頁101-102（2020年）。

論來說最大的問題已然不是其稀缺性，而是大量廉價的言論因為社群媒體投射並放大了原本使用者既有的主觀情感與意識型態框架之過程⁴⁴，而產生了極端化（polarization）的效應。

而言論稀缺被打破之結果，也使得牛津詞典2016年度收錄字彙所謂的「後真相（post-truth）」出現，意即就形塑公共論壇言論之影響力而言，客觀事實對個人之影響力遠不如訴諸其個人情感與信念之情況（circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief）⁴⁵。此種情狀與廉價（或譯為「便宜」）言論（cheap speech）打破資訊稀缺壟斷相關⁴⁶：由於原本擔任稀缺資訊（言論）無論是中介者（intermediary）或甚至進一步成為資訊守門人（gatekeeper）⁴⁷而（被要求）具有倫理與法律自律功能的傳統媒體角色，因為廉價言論帶來的資訊超載緣故，已被社群平臺上的用戶自媒體與融媒體聲量取代，而失去守門人把關的框架，使得言論市場上紛陳的資訊難以讓閱聽人（接收資訊者）詳加審議，只得選擇性地依賴社群媒體平臺之投放加以選擇，此種資訊失序也因此造成言論瀰泡。對此，

44 “when it comes to politics, facts make sense only within an ideological framework...Today, those political frameworks have fragmented and are shaped more by identity than by ideology...All this has led to anguished discussions about people living in echo chambers, sealed-off social worlds in which the only views they hear are ones echoing their own, and about the role of social media in creating such worlds.... More important, social media have not created a fragmented world. They merely reflect and amplify one that already exists, a world in which the authority of traditional institutions has eroded” Kenan Malik, *All the Fake News That Was Fit to Print*, N.Y. TIMES (Dec. 4, 2016), <https://www.nytimes.com/2016/12/04/opinion/all-the-fake-news-that-was-fit-to-print.html>.

45 *Word of the Year 2016*, OXFORD LANGUAGES, <https://languages.oup.com/word-of-the-year/2016/> (last visited Apr. 24, 2021).

46 關於美國學界對於廉價言論與表意自由相關歷史脈絡與學說介紹，參：陳柏良，AI-時代下機器的表意，2020年2月24日，https://www.acli.com.tw/acli_detail/66.htm（最後瀏覽日：2022年1月19日）。

47 See Natali Helberger et al., *Regulating the New Information Intermediaries as Gatekeepers of Information Diversity*, 17 INFO 50, 50-71 (2015).

學者亦指出既然在網路時代發表言論變得極其容易，使得其原本論理上受到保障的重大原因之一的言論稀缺性受到挑戰，而轉為廉價言論受到的注意（attention）⁴⁸，在廉價言論失序之狀態下，甚至可以倒過來成為言論審查之工具甚至武器⁴⁹；而新型態之言論管制則以透過網軍（troll army）引導話題的移轉、裙擺效應（西瓜效應，coattail effect）以及防止虛擬論壇使用者轉入現實社會等方式，透過焦點的移轉來改變輿論方向⁵⁰。

因此，對於不實訊息之管制焦點與其將視角凝視在事實或意見、評論等資訊本身，本文認為要點毋寧在於對資料／資訊投射放大的流動過程。換句話說，資料／資訊本身乃係中性，而失序地流動才是數位傳播時代應當聚焦之所在——這在以資料為驅動（data-driven）的社群媒體時代，更應當是當代民主社會行政管制之核心。

以國際知名防毒軟體賽門鐵克——諾頓在2019年所做之網路安全洞見全球報告的分析為例，該調查報告顯示許多矛盾衝突的個資保護與資訊隱私概念：即便是對於其隱私相當在意，但是總覺得已然太晚或是根本不可能能夠保護其隱私。而即便知道許多網路活動與應用程式對於隱私之保護有風險，但是卻只願意採取最基本之保護措施且覺得其本身不是最應負起責任保護其自身資訊之人⁵¹。以上的這些網路使用者線上行為，正是個人資料、隱私權以及資訊安全發生嚴重風險與損害結果的原因：中性的資料／資訊因為其中性

48 Tim Wu, *Is the First Amendment Obsolete?*, 117 MICH. L. REV. 547, 554-55 (2018).

49 Wu, *supra* note 48, at 558-59.

50 See Gary King et al., *How Censorship in China Allows Government Criticism but Silences Collective Expression*, 107 AM. POL. SCI. REV. 326 (2013); Gary King et al., *How the Chinese Government Fabricates Social Media Posts for Strategic Distraction, Not Engaged Argument*, 111 AM. POL. SCI. REV. 484 (2017)，轉引註自：陳柏良（註46）。

51 The Harris Poll, *2019 Cyber Safety Insights Report: Global Results*, NORTONLIFELock (Mar. 30, 2020), <https://www.nortonlifelock.com/content/dam/nortonlifelock/pdfs/reports/2019-nortonlifelock%20-cyber-safety-insights-report-global-results-en.pdf>.

之科技工具特質同時兼具著便利與風險，而該等風險伴隨的個資與隱私權侵害，也正是不實訊息造成民主焦慮的重大癥結。

而各社群媒體平臺依其各自特性，對於不實訊息之傳播散布有其不同的增益強化之處。歐盟議會關於不實訊息與政治宣傳的報告⁵²便指出就Facebook而言，因為其最為熱門，故其所有蒐集、處理與利用之個資量最大，而精準投放之效果也因此最佳，而其上的資訊（包括不實訊息）也被視為最值得信任，甚至成為許多人的日常生活新聞汲取來源，並且最有迴聲室效應下的「同溫層」歸屬感。需注意者，Facebook演算法言論濾泡傳播之訊息並非以訊息之真實性為判斷基礎，而是以蒐集個資最大化而使之易於擴散與精準投放訊息，藉以吸引使用者對相關廣告受到吸引與信任，乃至於發生黏著互動而為判準⁵³，但是基於不實訊息更易受歡迎之本質來看，在訊息流動的過程中成為不實訊息散播的最佳溫床。

另外，美國前總統川普愛用的Twitter則因為使用簡單與高度自動化，因此資訊（包括不實訊息）傳播速度最快，並且因為其允許單一使用者擁有複數帳號，因此匿名化程度最高，更易使惡意資訊傳播；年輕人愛用的Instagram與TikTok則因為使用者為年輕世代，較易受到個資侵害，且對於政治敏感性相對為低，易受政治宣傳影響，且以照片短影音為主的貼文容易製成迷因（meme）⁵⁴而使受到扭曲原意的迷因變成戲謔仿作之成果，規避法律規範之限制；YouTube的自動播放功能則一樣容易使得演算法過濾後之（不實）言論影片極大化散播。最後封閉性對話群組如Line、WhatsApp等，因為群組對話成員均有一定程度人際關係，因此資訊（包括不實訊

⁵² See Bayer et al., *supra* note 10.

⁵³ BENKLER ET AL., *supra* note 15, at 269.

⁵⁴ 迷因（meme）原指一個原創的想法，行為或風格從一個人跨到另一個人的傳播過程，在社群網路中，又被借轉為某一個有趣的觀念（例如加上字幕的圖片、影片）或一個在網路上（特別是社群媒體上）被廣泛轉載的東西。迷因在定性上係為以戲謔、嘲諷仿作之方式完成散布性高的傳述。

息)被更容易視為可信賴來源,且其封閉特性更不容易接受外來第三方之事實查證之檢核,也更易使得不實訊息傳播與難以更正⁵⁵。

基於前述說明,本文認為防止不實訊息造成風險與損害的方式之一,或許為對於該等訊息流動傳播途徑之治理。在資訊傳播的過程中,第一個環節即在於對社群媒體使用者個人資料的大量蒐集,以供作其後分析、對當事人人格剖析(*profiling*)其人格圖像,包括與民主社會極度相關的政治傾向(*political opinions*)、宗教與哲學信仰(*religious or philosophical beliefs*)等在歐盟被視作敏感性個資之個人資料⁵⁶。而個資當事人之人格圖像經過演算法剖析後,則被進一步地利用在群體分析以及原本被用做廣告的訊息精準投放(*micro-targeted messaging*)當中。此間,不實訊息之惡意傳播者即可透過購買廣告之方式,搭著社群媒體的便車與有效但是不透明的演算法⁵⁷,對大眾與社群成員進行轟炸式傳播,而此等傳播訊息之過程,正是問題的焦點。然而,該等管制如果以國家力量為行政管制,或是對社群媒體平臺管理業者課以資訊監督義務,則必然地碰觸言論管制是否能通過違憲審查的難題以及言論管制私有化體制之爭議⁵⁸。

⁵⁵ Bayer et al., *supra* note 10, at 38-39.

⁵⁶ Regulation (EU) 2016/679, of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) [hereinafter GDPR], art. 9, 2016 O.J. (L 119) 1, 38-39.

⁵⁷ 關於社群媒體演算法透明度與其控制資訊流與金流的問題,可參:FRANK PASQUALE, *THE BLACK BOX SOCIETY: THE SECRET ALGORITHMS THAT CONTROL MONEY AND INFORMATION* (2015).

⁵⁸ William Echikson, *Privatising Censorship*, CEPS COMMENTARY (May 14, 2018), http://aci.pitt.edu/93926/1/WE_FakeNews.pdf, 轉引自翁燕菁(註5),頁9。

參、個資保護作為切入點：先期階段的介入

如果意欲論述以個資保護之模式作為治理不實訊息傳遞之切入點，關鍵的問題在於在整個不實訊息在社群媒體的傳遞過程中，個人資料究竟在哪個階段被處理，亦即個資保護與不實訊息散布之因果歷程為何。首先，有別於在傳統媒體中，多數大眾無法個別表達其個別意見，社群媒體的使用者均有其表意自由而發表言論，然而也就是在這個言論分歧的階段，不實訊息可能出現。不過在這個階段進行管制與否之問題，則相對為單純就言論本身的管制，尚非本文聚焦。

第二個階段則是惡意者藉由社群媒體演算法對於使用者對不實訊息之傳遞（分享）予以分類並投放。目前言論市場上的廉價言論帶來資訊之超載，而現今相關之移轉焦點方式包括利用網軍、擴張裙擺效應等方式，將權利主體對於資訊之獲取與接收導入言論濾泡而造成受影響之社會疏離情狀。此時如果要以言論內容進行管制，勢必在一定程度上觸及資訊內容之真實性問題，不過基於言論濾泡傳播之訊息，尤其在虛假傳述之時，對於言論內容的真實性並非完全為其判斷基礎，而係以個資蒐集最大化之方式使之易於擴散與精準投放過程，以發生對特定資訊黏著。此階段過程中，又可被區分為數個不同的子階段：蒐集資料、個資主體人格剖析與精準投放等，而此即本文企圖以個資保護之規範作為治理依據之對象。

在以精準投放的方式散布不實訊息之前必須經由前一個先決的子階段，也就是大量地蒐集個資，以作為分析之來源。就以個資作為市場交易標的言，社群媒體提供免費或低價讓使用者發表言論的平臺，來交換他方使用者願意提供言論以及個資，並接收其他使用者言論。然則就其雙方交換行為來看，一個具有公平性質的交易行為至少必須包含交換客體以及交換過程必須在資訊上透明，以使得雙方得以評估願意交換的代價，而依其自由意志與對方以法律行為

方式作成法律關係。換言之，社群媒體與其使用者均須知悉其所放棄與將取得之利益而為理性交換，且雙方均非被強迫、僅有少數被限制之選擇⁵⁹，或其他限制選擇能力之情狀下為之。以英國個資保護委員辦公室（Information Commissioner Office, ICO）於調查劍橋分析案關於不實訊息之總結報告為例，可說明因為社群媒體之本質係為吸引更多用戶以便其擴充市場經營而獲得利潤，因此需要大量蒐集個資並且從個人資料掮客（data broker）、個資分析公司或其他資料中介者手中以未符合善良管理人注意義務、不符合個資公平處理原則（fair processing principle）、透明原則以及未獲個資當事人同意等方式獲得市場清單與個人生活資訊，做為剖析樣本⁶⁰。具體言，例如使用者在社群媒體對某公眾人物之言論按讚或其他表情符號，則研究者可把該使用者對某公眾人物之情緒表達，跟與該公眾人物之人格特質相關連，透過使用者的各種表達，並其他興趣及社群媒體上的各式活動結合，演算法便可透過剖析而預測該使用者在各種政治觀點的細微差異⁶¹。此際，與我國個資法第5條之蒐集最小原則與目的特定原則即生爭議⁶²；並須符合基於公開透明原則下第8、9條之告知要求⁶³。

另一個子階段則為精準投放（micro-targeting），其基礎在於前階段的資料蒐集在質與量越豐富時，其對使用者剖析越正確，則越

59 例如在因為國家政策緣故，使用者並無法選擇除該國政府允許之社群媒體以外之平臺。

60 Information Commissioner's Office, *Investigation into the Use of Data Analytics in Political Campaigns: A Report to Parliament*, at 8 (Nov. 6, 2018), <https://ico.org.uk/media/action-weve-taken/2260271/investigation-into-the-use-of-data-analytics-in-political-campaigns-final-20181105.pdf>.

61 See, e.g., Hideyuki Matsumi, *Predictions and Privacy: Should There Be Rules about Using Personal Data to Forecast the Future?*, 48 CUMB. L. REV. 149, 160 (2017).

62 詳參：翁清坤（註43），頁122-123；翁逸泓，科技人權——全民電子通訊監察與個人資料保護，臺灣民主季刊，15卷1期，頁26-27（2018年）。

63 劉定基，大數據與物聯網時代的個人資料自主權，憲政時代，42卷3期，頁283（2017年）。

提高精準投放成效。精準投放之類型有二，其一為商業廣告行銷，其二則是非商業類型。那麼精準投放的本身就個資保護之觀點言，問題又在何處？

1. 人格剖析（**profiling**）係指以個人資料處理技術為潛在之後續使用而將當事人剖析，特別是為了得到其決策，或為分析或預測其個人喜好、行為及態度。其本身為資料驅動（**data-driven**）過程，在GDPR（**General Data Protection Regulation**）中關於公平透明處理原則即要求個資控管人需通知個資主體受處理方式及其目的，包含資料之剖析及其剖析結果、其是否有義務提供個人資料與不提供該等資料時之結果等事項應以標準化之標誌方式通知該個資主體⁶⁴，因此剖析之行為以及其基於該剖析所得之決策受到GDPR拘束⁶⁵。另方面，在此利用限制階段，則可能發生對於個資再利用之問題，而分別涉及我國個資法第15、16、19與20條等⁶⁶。
2. 以精準投放本身言，其之所以極度有利於廣告效果，原因在於該等技術之原理乃是瞄準個人在人性上的弱點（例如興趣、偏好、好奇、嫉妒與期待等特質）與恐懼等⁶⁷，而誘發個人行動。也因為精準投放此種性質，因此對於人性尊嚴、人格權及隱私權言，有一定程度之侵害可能⁶⁸，而基於自動化剖析之精準投放所影響之個資當事人決策情狀、行為以及選擇等，均受GDPR第22條規範，但我國則無相關個資法上之規定。

64 GDPR, recital 60, 2016 O.J. (L 119) 1, 12; art. 13, 15, 2016 O.J. (L 119) 1, 40-41, 43.

65 GDPR, recital 72, 73, 2016 O.J. (L 119) 1, 14; art. 21, 22, 2016 O.J. (L 119) 1, 45-46.

66 詳參：翁清坤（註43），頁95-101；翁逸泓（註62），頁28-30。

67 Frederik J. Zuiderveen Borgesius et al., *Online Political Microtargeting: Promises and Threats for Democracy*, 14 UTRECHT L. REV. 82, 87 (2018).

68 Bayer et al., *supra* note 10, at 74.

以GDPR第22條第1項來看，個資當事人應有權不受僅基於自動化處理（包括剖析）所做成而對其產生法律效果或類似之重大影響之決策所拘束。在此需要討論者，係GDPR本身並未詳細定義何謂「類似之重大影響結果」，至多可以在其前言第71點找到GDPR舉的例子：例如網路信用貸款申請時，因為信用評價負評而產生之自動拒絕，或不包括任何人為介入之電子化人力招募。又或者從第22條第2項推論出的基於對個人自動化決策生成的締結契約行為。

不過在文獻上則有提出以投放廣告之行為是否合於「類似之重大影響結果」之討論，論者認為基於投放廣告之結果未必立即造成如同GDPR前言舉的例子一樣生成拒絕放貸、拒絕聘用或是締結契約的法律效果，因此恐怕不能說是適合的情狀⁶⁹。不過，當投放廣告造成對於特定相對人提供不同待遇時，仍應該被認定是此處之類似法律效力的重大結果。本文認為，在此考量之點有二：其一，是否產生差別對待之結果；其二，發生了壟斷資訊之結果。前者的原因是因為該等決策結果可能是基於一個具有偏見或歧視的演算法（而這點在發展人工智慧應用時，被歐盟列為重大核心原則如前述），或是結果之誤差；後者則是基於對資訊的壟斷將形成個資當事人基於資訊之缺乏而產生不對稱之決策結果。此際，包括避免偏見或歧視、提供一個合適的數學或統計程序以避免誤差等，均在GDPR前言第71點可尋得論理依據。而不實訊息正是基於其作假與誤導性質，而特別容易導致差別對待與壟斷結果；另一方面，資訊壟斷以及精準投放之行為，也相對地容易提升誤導等不實言論之損害風險與侵害結果。

⁶⁹ Joachim Schrey, *General Conditions for Data Processing in Companies under the GDPR*, in NEW EUROPEAN GENERAL DATA PROTECTION REGULATION: A PRACTITIONER'S GUIDE 105, 149-50 (Daniel Rücker & Tobias Kugler eds., 2017).

3. 以商業行銷為目的之精準投放類型：無論是依據GDPR第21條第2項或是我國個資法第20條第2項，當個人資料之處理係以直接行銷為目的時，資料主體有權拒絕該處理。另外於GDPR中更明示範圍包括在與直接行銷有關之範圍內之剖析，而不問係原始處理或進階處理。

此種類型關於社群媒體將個資用於投放廣告，在2019年7月歐盟法院即有判決⁷⁰：一名消費者因為他在網購衣物Fashion ID平臺上按Facebook「讚」的同時，該購物網站竟洩漏了其個資，因此其向德國法院提起訴訟，德國法院上呈至歐洲法院尋求解釋，歐洲法院對此判決Fashion ID就將個資交予Facebook後之部分已不具備個資控管者資格而毋需負責，然在前階段包括對個資當事人個資之蒐集與交付（處理）予Facebook等，則Fashion ID與Facebook為共同個資控管者（joint controller），此時需在蒐集個資時善盡告知義務，未來網路（行銷）平臺若要在網站上植入Facebook按讚，必須告知使用者相關個資（如IP位址等）可能會傳到美國Facebook的總部，也需要清楚告知使用者Facebook所有的網路使用規範。有趣的是，在此判決之後，Twitter即在2019年8月初發表聲明稱，由於社群平臺設置「有問題」而出現未經用戶許可蒐集用戶包括可能涉及用戶的所在地、與特定廣告內容的互動和用戶使用的裝置等個人資料，將其用於分析用戶偏好以提高廣告投放的準確率，故此後將改善該等「問題」⁷¹。

⁷⁰ Case C-40/17, Fashion ID GmbH & Co.KG v Verbraucherzentrale NRW e.V., <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62017CC0040>; Case C-210/16, Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein v Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62016CJ0210>.

⁷¹ *An Issue with Your Settings Choices Related to Ads on Twitter*, TWITTER, <https://help.twitter.com/en/ads-settings> (last visited Apr. 24, 2021).

然而，無涉不實訊息或是誤導性之商業性廣告，因為未涉及戰略與政治宣傳之投放廣告類型，在歐盟對於不實訊息之定義上，並未被包括在被討論之範圍之內，並且不妨礙有約束力的法律義務、自律廣告準則和誤導廣告的標準，也因此此部分並非在本文主要關懷之範圍。

4. 在非商業行銷類型，而需特別注意者即為政治宣傳類，包括國家、政黨與政治人物等，對於政治宣傳之操作，而這也是目前對於民主社會為患最為嚴重的不實訊息類型。

對於此類型，本文認為需延伸論理者有二。首先，關於政治意見之言論是否能逕為蒐集，於我國個資法第6條特種個資原則上不得蒐集之類型，僅包括病歷、醫療、基因、性生活、健康檢查及犯罪前科等，而不及於GDPR第9條關於「揭露種族、政治意見、宗教或哲學信仰」之個人資料類型。對此，本文認為這或許是在關於對民主社會侵害嚴重的政治宣傳不實訊息中，歐盟個資保護相較我國保護密度落差最關鍵處之一。而這些資料類型無疑地係形塑內在人格發展的重要基礎，並與民主社會緊密關聯，如果這些類型的個資被任意蒐集後加以剖析，形成人格圖像，則嚴重地增加了政府或其他個資控管者監控與窺知個人政治思想之風險，也對資訊隱私之內涵造成侵擾，則其在本質上應被視為係對於基本權利與自由係為特別敏感之個資。這在我國歷經威權時期，人民過往無端地被任意蒐集個人政治傾向資料之經驗下，更應當謹記；再對照我國現今於實踐民主程序中無論是選舉當下或選後所受到之內在與外來不實訊息擾動之威脅，不實訊息之攻擊不但未曾因為大型選舉結束而減緩，且其傳播係為跨社群平臺連動呼應之方式，除了造成個資權利受到

影響，也大幅降低社會成員間彼此之信任關係之損害結果⁷²，本文因此主張我國個資法未來或可考量將此納入特種個資之類型。

然而，如果將所有涉及「人格發展」與「民主社會公共事務討論」之言論均納入政治言論之範疇，而以特種地位個資之地位加以保障，則或許因為特種個資保障之強度過高，而使得意圖遮蔽個資之人均將言論資訊納入特種個資範圍，而不予以揭露，這在關於政府資訊公開之情況，尤其可能產生失衡。以歐盟法院 *Egan and Hackett* 案⁷³ 來說，歐洲議會認為如果揭露其前議員助理之意見，會連帶地揭露該助理的政治意見，則因為政治意見是特種個資，不應任意蒐集處理與利用，因此拒絕公開。法院則認為必須證明該等政治意見個人資料之揭露將具體而有效地損害在網路上之隱私權，方得將其視為政治性意見之範疇⁷⁴。

又，政治宣傳之精準投放（political micro-targeting）雖然未如直銷之商業類性直接被規範於GDPR與我國個資法，但基於其高度敏感性而與人格最私密之形塑相關連程度，並與民主社會投票權行使基礎（相關政治資訊與信仰）之影響⁷⁵，本文認為如該等言論在社群媒體上之蒐集、處理與利用而有

72 Nick Monaco et al., *Detecting Digital Fingerprints: Tracing Chinese Disinformation in Taiwan*, IFTI (Aug. 2020), https://www.iftf.org/fileadmin/user_upload/downloads/ourwork/Detecting_Digital_Fingerprints_-_Tracing_Chinese_Disinformation_in_Taiwan.pdf.

73 Case T-190/10, Kathleen Egan and Margaret Hackett v. Parliament, Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 28 March 2012.

74 *Id.* at para. 101.

75 See European Commission, *Commission Guidance on the Application of Union Data Protection Law in the Electoral Context: A Contribution from the European Commission to the Leaders' Meeting in Salzburg on 19-20 September 2018*, at 8, COM (2018) 638 final (Sept. 12, 2018), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TEXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0638&from=EN>.

影響個資當事人之選舉活動行為或在民主社會體系將影響個資當事人之民主決策行為⁷⁶，例如學者舉例之與特定政黨有隸屬關係、參與遊行、政治宣言或政治出版活動等⁷⁷具有能證明其揭露將生具體之隱私權實害時，則除非有特種個資蒐集之例外情狀，否則原則上應視為敏感性之特種資料而予以禁止。再者，被歸類為特種個資的政治意見，其豁免而得處理情狀也應當採取限縮之解釋⁷⁸。

而在這些個資處理的階段中，本文認為在個資大量蒐集之子階段，厥為個資保護模式在治理此問題上最為關鍵之所在，這是因為：

1. 個資之大量蒐集為其後精準投放不實資訊之先決必經階段，而其後精準投放之階段可能依賴的是社群媒體各自不同之演算法，但無論演算法為何以及是否涉及或違反個資保護或言論管制之原則，社群平臺的推播機制或許都會使得該等資訊隨後的傳遞變得容易，形成自然的散布。
2. 而此一階段大致上僅與個資保護相關，而未牽連關於言論自由之管制問題，使得個資保護模式的輔助（言論管制）作用更加明顯。
3. 如為惡意企圖藉由社群媒體散布不實訊息之攻擊者，亦可能透過資料掮客或其他中介者大量蒐集個資以作分析或預測之用。

⁷⁶ See GDPR, recital 56, 2016 O.J. (L 119) 1, 11.

⁷⁷ Ludmila Georgieva & Christopher Kuner, *Article 9 Processing of Special Categories of Data*, in THE EU GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR): A COMMENTARY 365, 375 (Christopher Kuner et al. eds., 2020).

⁷⁸ European Data Protection Board, *Statement 2/2019 on the Use of Personal Data in the Course of Political Campaigns*, at 2 (Mar. 13, 2019), https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb-2019-03-13-statement-on-elections_en.pdf.

4. 基於風險的前期預防性效果較佳，以及個資保護的前置設計與預先置入（data protection by design and by default）原則，早期置入個資保護之原則與機制乃是重要的保障措施。

而此處於早期個資大量蒐集階段所應特別考量之個資保護基本原則，本文認為或許可依照英國資訊委員在劍橋分析案與民主滋擾問題的報告書中所總結的，至少需特別考量課責與透明原則：雖然此二原則並非新增加之個資保護原則而係早已存在，但是由於GDPR強化個資當事人對其個資將如何利用以及為何種目的蒐集之控制可能性，因此更顯得此二原則在資料科技應用時代之重要程度⁷⁹。

綜言之，本文認為保護隱私以及個人資料，毋寧為數位時代社群媒體出現精準投放不實訊息之際，保障民主健全的重要基礎與先決措施⁸⁰。而以個資保護作為管制不實訊息之方法，除了可以與言論自由之保障相互合作結合以外，也可以有效地補充處理關於牽涉資訊接收與獲取之利益，而與言論自由無法直接關聯之問題。在這裡需要特別提到的是，本文並不認為應當捨棄言論自由在不實訊息管制模式中所應扮演之角色，而是強調個資保護之管制方法在類型上與有效性上，可以與言論自由並行，強化並補充管制效果。故，本文認為以個資保護之模式作為管制不實訊息是「補充／結合」關係，而非「競合／取代」之關係，意思是個資保護模式仍可以在既有（不完美而屢生爭議）的言論管制模式框架內展開，而不會推翻

⁷⁹ Information Commissioner's Office, *Democracy Disrupted?: Personal Information and Political Influence*, at 7 (July 11, 2018), <https://ico.org.uk/media/2259369/democracy-disrupted-110718.pdf>.

⁸⁰ See also Alice Thwaite, *Literature Review on Elections, Political Campaigning and Democracy*, at 1, OXFORD TECHNOLOGY AND ELECTIONS COMMISSION, UNIVERSITY OF OXFORD (Sept. 2019), <https://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/2019/09/OxTEC-Literature-Review-Alice-Thwaite-Report-25-09-19.pdf>.

傳統觀點，也非一種獨立的管制方法⁸¹。在下一部分，本文首先便對言論自由與個資保護之可能出現的緊張關係，加以處理。

肆、實際踐行：界限與策略

一、言論自由作為民主基石的要素

在任何對於線上訊息傳遞流通治理問題中，首先遇到的挑戰厥為治理活動中對言論之管制所可能出現的對於基本權利限制與民主爭議。

言論自由這個基本權利事項所保障者，其權利主體如果從表意人角度出發之論點來看，因為表意人有表達其個人見解以追求自我實現的權利，從而保障之對象或許僅為表意者本身，則似難以包括閱聽眾之接收訊息者。然，文獻指出憲法中的言論概念係「權利主體——亦即表意人和閱聽人——」之間的意義傳遞（meaning transfer）⁸²，在此，似乎可以進一步地被詮釋為憲法上保障的言論自由之權利主體包含了表意人與閱聽人，甚至是再從真理觀點切入，既然真理只能透過言論的公開競逐而達致，則保護之對象在這兩種脈絡下考量或許在解釋上能包含對閱聽眾之接收訊息者權利，而憲法也保障了言論本身之傳遞。進一步地細究，前述憲法所認知的言論概念必須具備了「表意性（expressiveness）」與「社會性（Sozialbezug）或主體間性（intersubjectivity）」兩項要件，而關於主體間性／社會性在解釋上更是「預設了表意人和閱聽人雙方，以

81 關於此種「補充／結合」關係，學術著作在分析法學方法時，也將之應用在關於法律經濟分析方法與法釋義學關聯上。參：王鵬翔、張永健，論經濟分析在法學方法之運用，臺大法學論叢，48卷3期，頁797-798（2019年）。

82 蘇慧婕，言論管制的中立性——美國雙軌理論和德國一般法律理論的言語行為觀點分析，收於：李建良編，憲法解釋之理論與實務（九），頁209（2017年）。

及主體之間的溝通連結」(粗體強調為本文作者所加)⁸³。

續從言論主體間的溝通連結來看，本文在前節已說明認為既然稀缺性已不再是言論本身之問題，重點毋寧在於已然發生了的資訊(言論)失序情狀，因此在新興社群媒體發展之情況下，維護意見市場保有一定程度之競爭性或許需要重新考量⁸⁴：於社群媒體時代，選擇取得資訊的管道因為新興媒體的普及而變得更加多元，而自媒體時代社群媒體使用者也不再是單純的資訊接收者(B)，而同時也成為發出言論者，甚至在臺灣現行諸如「爆料公社」等人手一臺手機鏡頭隨時製播即時畫面，而新聞媒體記者也潛伏各大社群媒體報導前述使用者提供畫面之時，在不缺乏言論的資訊失序的情況下，衡量意見多元之標準已然難以確認⁸⁵。

再就民主爭議言，網際網路所承載的社群媒體以傳統民主理論至少可以安置三種類型的民主要素⁸⁶：選舉、監督與審議⁸⁷。細究之，網際網路以及社群媒體在該等民主觀當中最重要貢獻乃是提供民主社群成員參與的機會與場域，而這個參與以哈伯瑪斯的論理而言，乃是提供對話且考量不同見解之可能⁸⁸，而Carl Schmitt也將民

83 蘇慧婕(註82)，頁210-212。

84 劉靜怡，媒體所有權、觀點多元化與言論自由保障：美國法制的觀察，臺大法學論叢，40卷3期，頁1134(2011年)。

85 劉靜怡(註84)，頁1136。

86 Graham Longford & Steve Patten, *Democracy in the Age of the Internet*, 56 U.N.B.L.J. 5, 5 (2007).

87 審議式民主(deliberative democracy)約略為民主社會參與者皆有公正、平等的參與機會，定期或不定期於特定的公共場域，在掌握必要的資訊後，於一定規範的進程序下，以共善及公共利益為考量基礎，理性的以各自觀點及立場公開論理並相互對話，審慎思辯公共事務相關議題，尋求意見之整合或共識之凝聚，作為政治體系決策的重要參考方案，進而增進公民知能及民主政治文化。哈伯瑪斯對此以其discourse theory of democracy作為基礎嘗試建構審議式民主概念。

88 See generally JÜRGEN HABERMAS, MORAL CONSCIOUSNESS AND COMMUNICATIVE ACTION (Christian Lenhardt & Shierry Weber Nicholsen trans., MIT Press 1990) (1983). See also JÜRGEN HABERMAS, JUSTIFICATION AND APPLICATION: REMARKS ON DISCOURSE ETHICS (Ciaran P. Cronin trans., MIT Press 1993) (1985).

主定義為以公共論壇維繫之政府⁸⁹。由此可見至少線上之表意與言論自由，不僅為國際人權文件⁹⁰以及民主國憲法上保障的基本權利事項，亦為民主社會之重要基石⁹¹。

以哈伯瑪斯前述論理而觀，重點在於（任何的一個）表意人作為行動的主體必須有機會可以發表言論而不遭受壓制，此後透過意見的理性與公開交流達成溝通，做成決定。本文認為這個論理後半段關於（一個以上）意見的理性（*rational*）與公開（*public*）交流，在行為上應該包括第一個行為(I)發出言論者(A)的發表言論以及閱聽眾(B)之接收言論資訊後，接續的(B)作為表意者在接收資訊後決定發表言論，成為第二個行為(II)。在(I)、(II)乃至在社群中的發言者之間完成複數行為(N)後的交流發生連動後，才能獲致民主決策基礎，而這個概念亦能在追求真理說當中，獲得相同解釋。

哈伯瑪斯民主論觀點的概念內涵也與Sunstein所持促成審議民主中的共識形成以及Edwin Baker複雜民主理論在其所主張的維護公共領域的討論品質有若干契合之處⁹²。這個論證，或許可以很有趣地在相對極大化溝通立場的言論自由保障相關判決中，獲得進一步啟發。在*Jian Zhang et al. v. Baidu.com Inc.*案中⁹³，一群紐約居民因認百度（中國搜尋引擎）在美國阻擋了中國關於民主的相關資訊之搜尋結果係違法，因此向法院提出控告。對此，百度抗辯其演算法與其所導出的搜尋結果均為美國憲法第一修正案所保障之言論範疇。承審法官接受百度之抗辯，並指出搜尋引擎之搜尋結果為其編

89 CARL SCHMITT, *CONSTITUTIONAL THEORY* 275 (Jeffrey Seitzer trans., Duke University Press 2008) (1928).

90 *E.g.*, International Covenant on Civil and Political Rights art. 19, Dec. 16, 1966, 999 U.N.T.S. 171; European Convention on Human Rights art. 10, Nov. 4, 1950.

91 另參：林子儀，言論自由之理論基礎，臺大法學論叢，18卷1期，頁227-275（1988年）。

92 關於民主論在言論管制理論證成的詳細討論，參劉靜怡（註84），頁1089-1174。

93 *See Jian Zhang et al. v. Baidu.com Inc.*, 10 F. Supp. 3d 433 (S.D.N.Y. 2014).

輯決定，亦即網站所有人展現其如同報章雜誌編輯權之領域⁹⁴，具有言論自由之保障。對此，Emily B. Laidlaw認為這個判決忽略了即使媒體也應有維持公共利益之社會責任；並且在歐洲基於歐洲人權公約第10條之保障關於保障多元觀點的國家積極義務，因此該判決或許無法於歐洲維持⁹⁵。然而無論是就該判決本身，又或是對其批判之觀點，本文認為套用前述公式將百度(B)作為接收使用者(A)搜尋(I)作為表意的閱聽後，由百度(B)回饋(II)出搜尋結果，而該搜尋結果即為百度（作為表意人）(B)之表意(II)，使得使用者(A)接收。對此，純就言論自由之角度觀察，則法院認為搜尋之結果為百度(B)之言論表意(II)而認為屬於言論保護之範疇，然而，如果加上客觀事實：百度(B)在中國之搜尋引擎市場幾乎具有壟斷性，則百度(B)排除掉民主概念之搜尋結果(II)，在相當程度上也會對於使用者(A)的資訊隱私權及資訊自決權，造成嚴重之影響，並有相當大的機會造成使用者(A)人格自由形塑之扭曲。

不過言論自由雖然如上所述係為民主社會重要基礎，而即便是線上言論本身對民主有其增進溝通、對話機會重要作用，但是也有可能反過來對民主形成威脅，這在以社群媒體為潮流的數位通訊傳播年代，更是如此：哈伯瑪斯在其後的論文中也反思到以電腦（網路）為取徑的對話，可能低估了威權體制以此反過來控制與改變公共意見的威脅：與原本期待網路形塑一個巨大公共對話論壇的理想不同，社群媒體的發展使得對話群各自依其政治意見與哲學信念隔絕為無法相互溝通的迴聲室。在此，無法凝聚共識反而更造成意見

94 關於我國的媒體編輯自由與個人近用媒體權之競合問題，大法官對此認為「接近使用傳播媒體」與「媒體的編輯自由」具有基本權衝突的問題。「如無條件強制傳播媒體接受民眾表達其反對意見之要求，無異剝奪媒體之編輯自由，而造成傳播媒體在報導上瞻前顧後，畏縮妥協之結果，反足影響其確實、公正報導與評論之功能。是故民眾『接近使用傳播媒體』應在兼顧媒體編輯自由之原則下，予以尊重」。參司法院釋字第364號解釋。

95 EMILY B. LAIDLAW, REGULATING SPEECH IN CYBERSPACE: GATEKEEPERS, HUMAN RIGHTS AND CORPORATE RESPONSIBILITY 209-11 (2015).

分歧與僵化的線上之對話言論，事實上並無法完全發揮審議上的決策功能，而僅只能作為發聲之管道，反過來限縮了民主的發展甚至造成退潮（retreat）⁹⁶。換句話說，此時基於迴聲室之效應，網路與社交媒體賦予權利主體快速爬梳接收獲取之資訊內容之能力，並透過演算法強化基本社會心理傾向互動面向，達成確認權利主體本有之偏見，並凝聚同溫層，再進一步地避免使用不符合該等權利主體所知與所欲接收、獲取之資訊。此種現象造成各個迴聲室的群體不會傾向於接收、獲取對立之資訊，使得媒體生態碎片化，讓整個言論市場上產生了極端化之疏離現象⁹⁷。

何以致此？Laidlaw對此歸納指出首先社群媒體平臺與線上言論並非決策工具，而僅只是對話工具，因此並不能宣稱符合前述哈伯瑪斯關於理想言說情境（ideal speech）所設定的：所有參與者都有相等的機會，參與陳述、表意和規約（regulative）的言語行動，在沒有任何不公平或強制的條件下，進行平等而真誠溝通與對話，並排除只具單方約束力之規範和特權等眾多條件下的內涵⁹⁸。再者，完整審議式民主決策尚需要有公共論壇機制作為要件，而以網路平臺作為對話論壇雖然看似提供了一個沒有空間限制的集會場而一度被認為是公開場域，但是哈伯瑪斯本人後來卻認為網路因為其言論的雜沓而無法使公民專注對話之議題⁹⁹，因此Laidlaw認為網路上爆量的資訊並無法直接轉換為「理性」溝通所需要的前提基礎資訊，而網路去中心化控制的特性也使得社群平臺無法成為「一個」公共論壇，而是被區分為數個彼此隔離無法交流的大型論壇¹⁰⁰。

96 Habermas, *supra* note 37, at 423.

97 See CASS R. SUNSTEIN, #REPUBLIC: DIVIDED DEMOCRACY IN THE AGE OF SOCIAL MEDIA (2017); BENKLER ET AL., *supra* note 15, at 24, 290.

98 LAIDLAW, *supra* note 95, at 12-13.

99 Stuart Jeffries, *A Rare Interview with Jürgen Habermas*, FINANCIAL TIMES (Apr. 30, 2010), <https://www.ft.com/content/eda3bcd8-5327-11df-813e-00144feab49a>.

100 LAIDLAW, *supra* note 95, at 14-17.

此外，基於本文前述關於不實訊息在社群媒體平臺上對民主所造成之威脅，愈發使得理想言說情境中關於理性之要求條件，產生偏差。取而代之的言說基礎，反倒是經常在社群媒體上遇見的基於激情政治意見與宗教、哲學信仰的認同所決策的民主決定¹⁰¹。另一方面，數位通訊傳播時代資訊量膨脹造成面對的公共議題在質與量上的複雜多樣化，即便「正確」的資訊隨手可得且大多數的不實訊息理應可以查證，但是基於社群平臺上的言論並非建立在「一個」能彼此溝通的公共論壇（言論市場）上，因此使得心中有既定意識形態的閱聽人／資訊接收者在閱讀不同訊息的情況下，仍會獲得相同的價值觀¹⁰²：這正是前述迴聲室效應的表現。也因此如同本文前述提及，在封閉的對話群組中，即便更正澄清不實訊息，事實上也无法有效更動成員之價值選擇。換言之，在這樣的情況之下，封閉而獨立的各群組所信賴的對象與其為民主社會的整體論壇，毋寧為無法溝通的閉鎖政治思想與哲學信仰迴聲室。另一方面，在個別迴聲室中訊息即便有誤或是偏差，但是基於言論自由關於尋求真理說的觀點而言，因為錯、假訊息正是尋求真理的過程當中需要被細細考量的必經途徑¹⁰³，因此禁止該等訊息的發表，對於言論自由與民主來說，一樣不利。

最後，在包括演算法、人工智慧與其他數位資通訊技術逐漸能夠應用於社群平臺言論（包括不實訊息）之現代，該等人工智慧所為之言論，因為其言論表意者已非憲法上原本所要保障的權利主體，則是否符合言論自由理論中保障表意者自我實現之論理，乃至於前述憲法保障言論中關於社會性／主體間性之要件是否仍能維持，不無疑問。

101 See generally, e.g., FRANCIS FUKUYAMA, *IDENTITY: THE DEMAND FOR DIGNITY AND THE POLITICS OF RESENTMENT* (2018).

102 See SUNSTEIN, *supra* note 97, at 31-58.

103 JOHN STUART MILL, *ON LIBERTY: WITH RELATED DOCUMENTS* 50-58 (Alan S. Kahan ed., 2008).

綜上，雖然言論自由為基本權利與自由保障範疇，但仍有其限制，例如與其他基本權利競合時關於比例原則之考量，又或為確保民主社會價值存續，而可能對言論進行管制。對此依據學者分析，德國的歐洲類型言論管制與美國的言論管制基於各自憲法文義基礎、政治社會背景，以及對具體司法個案證成模式不同，而有不同寬嚴程度之限制¹⁰⁴。然而無論如何，如學者所言，言論市場的自由放任並不能擔保真理的勝出；彼此隔閡的回聲室更無法成就言論市場的自由化¹⁰⁵。此際，同時繼受二者脈絡的我國立法規範與司法實務，又該如何操作言論限制而能通過違憲審查，便成為在對抗不實訊息時難以迴避的困難問題¹⁰⁶。

須注意者，此論理脈絡並非意味著不需要理解並分析言論管制相對應之司法審查標準，而此一審查標準之再建構，也一直是國內外文獻目前討論的重要焦點。以行政院相關對抗不實訊息之政策宣示言，「有法律保留原則及司法審查原則的前後把關，這二重的保護機制，應該可以把影響言論自由的風險降到最低」¹⁰⁷。依本文前述論證，在社群媒體時代關於不實訊息管制最主要之問題癥結在於傳播之過程，那麼與言論自由權利同時並存的資訊權既然也牽涉其中，其能夠作為管制基礎之論理，以及相對應的司法審查基準，也應當被審視。

二、個資保護與言論自由的緊張關係

本文前述討論說明了在言論（資訊）的傳播過程中，基於資訊

104 蘇慧婕（註82），頁201-269。

105 蘇慧婕，假訊息管制與資訊揭露義務——以選罷法、公投法及其修正草案為中心，月旦法學雜誌，292期，頁44（2019年）。

106 關於網路言論內容之管制與網路中介者之角色與權力問題，有其事關於言論自由與其限制之爭議的困難之處如「編輯裁量權」（editorial discretion）之考量等，詳參：劉靜怡，網路內容管制與言論自由——以網路中介者的角色為討論重心，月旦法學雜誌，192期，頁63-80（2011年）。

107 參外交國防法務處（註19），頁10。

的接收本質上同時涉及了言論自由與資訊隱私、資訊自決等權利態樣，故而個資保護僅是相關治理所需衡平之基本權利之一，因此本文在建構對投放傳遞不實訊息之個資保護模式作為治理原則時，對言論自由與個資保護之可能出現的緊張關係，必須釐清該等治理手段與言論管制之間的關聯性，以及管制個資處理（投放不實言論之傳播過程）的對應司法審查標準為何。

（一）個資保護模式之資訊治理與言論自由管制

言論自由與私生活權利下的隱私權保障及個資保護之權利競合問題，並非一個全新的研究主題，但卻無疑地是個難解的問題。以歐盟GDPR¹⁰⁸正式生效後的第一個個資保護與新聞自由衡平之爭議案件為例¹⁰⁹，或許可以進一步觀察GDPR下個資保護概念與新聞與言論自由之競合問題：2018年11月5日羅馬尼亞當地新聞報導一名政客貪污案件，但是該報導之記者立即遭到羅馬尼亞的個資保護獨立機關（The National Supervisory Authority for Personal Data Processing, ANSPDCP）行政調查，詢問記者之消息來源以及編輯允許上架之責任。由於新聞媒體保護消息來源向來是新聞自由與倫理的重要課題¹¹⁰，因此在遭受國內相關媒體質問是否侵害新聞自由時，ANSPDCP回應宣稱其為獨立個資專責保護機關，本於職權獨立，將妥適地衡平言論自由與個資保護權利的相關資訊權。

準此，無論是歐盟或ANSPDCP都必須進一步地考量關於GDPR第85條關於言論與資訊自由對於個資保護權利之調和，也正

108 GDPR, 2016 O.J. (L 119) 1-88.

109 #TeleormanLeaks Explained: Privacy, Freedom of Expression, and Public Interest, PRIVACY INTERNATIONAL (Nov. 21, 2018), <https://privacyinternational.org/news-analysis/2456/teleormanleaks-explained-privacy-freedom-expression-and-public-interest>.

110 參：林子儀，新聞自由的意義及其理論基礎，臺大法學論叢，22卷1期，頁84（1992年）。

因為如此，歐盟境內多個隱私與人權保護團體均致函要求歐盟個資保護委員會（European Data Protection Board, EDPB）儘速提出相關治理指引（guidance）。

此際，關於GDPR第85條言論自由與個資保護之衡平，探究個人資料保護在社群媒體言論管制中所扮演之角色時，即必須詳為檢視。就GDPR第85條第1項言，其規範：「會員國應以制定國內法之立法方式，調和GDPR所定個人資料保護之權利及表意自由與資訊自由，該等自由包括新聞目的及學術、藝術及或文學表意目的之處理」（粗體強調為本文作者所加）。一方面除此處GDPR將表意與資訊自由並列，可供支持本文前述論證外，另方面，也說明對於表意自由之管制，可藉個資保護諸權利相關法制之規範與其實踐加以「調和」¹¹¹。那麼，接下來的爭點便在於：何種情況下對於個人資料之保護權利在行使後，會發生限制言論自由與新聞自由之可能呢？

前案中，羅馬尼亞對於GDPR第85條，落實在其國內法no. 190/2018第7條¹¹²中就個資允許為新聞目的處理之例外有三：(1)由

111 GDPR 在第 85 條第 1 項所謂給予會員國調和空間，也就是「排除（derogation）」，係指會員國可基於本國法律體系或國情而對某些特定之條文規範不予適用。例如，英國在落實GDPR之內國立法Data Protection Act 2018 (DPA 2018)中，對某些規範在適用條文而被違反之情狀下，對行為人給予豁免（exemption）其義務或處罰。另一方面，也在DPA 2018附件2第5部分第26條第6項，指定實踐準則與指引，分別是BBC編輯指引（BBC Editorial Guidelines）、英國通訊管理署廣播指南（Ofcom Broadcasting Code）、編輯實踐準則（Editors' Code of Practice）。這些準則則是給予實務應用上充分的參考依循。

112 See ANSPDCP, *Press Release*, ANSPDCP DATAPROTECTION ROMANIA, https://www.dataprotection.ro/?page=Legea_nr_190_2018&lang=en (last visited Apr. 24, 2021.); for English edition, see The Romanian Parliament, *Law No. 190/2018 on Measures for the Application of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and Council of 27 April 2016 on the Protection of Natural Persons with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of Such Data, and Repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)*, https://iapp.org/media/pdf/resource_center/Romanian_Data_Protection_Law_English_Translation.pdf (last visited Apr. 24, 2021).

個資當事人明示公開其個資；(2)資料當事人為公眾人物，且其個資與其身為公眾人物之原因緊密結合；以及(3)個資與個資當事人牽涉之公眾行動的特徵緊密連結。然而，從新聞自由與個資保護之衡平角度觀之，羅馬尼亞此種GDPR之國內法化事實上對於新聞自由相對地採取較為緊縮限制之立法¹¹³。換句話說，在實務上已然出現以個資保護法制之模式對言論進行管制的情狀。不過，這個案例也可以觀察到即便可以個資保護法制之模式對言論自由進行管制，但此等立法之規範與實務操作也可能對於新聞自由過度緊縮設限，因此歐盟執委會強調此種行為可能造成對於GDPR之過度濫用¹¹⁴。

再進一步地聚焦在本文所關懷的社群媒體平臺方面，其對於個資蒐集的預設禁止保護作為在實踐上也受到許多中、小型廣告主以及個人使用者之質疑，認為在其個資權利受到該等「保護」的情況下，反而不利於使用者自身之言論擴散，以致使得言論之自由程度受到減縮。以Apple近來企圖強化對於使用者之個資保護的作為為例，便引來Facebook關於包括侵犯言論自由與壟斷市場之抗議：Apple計畫在iOS 14.5之版本落實要求應用程式開發者必須獲得使用者同意該應用程式蒐集廣告識別碼（Identifier for Advertising, IDFA），才能透過應用程式追蹤使用者的日常活動軌跡並分享資料予第三方，藉以強化Apple產品之隱私保護與透明框架¹¹⁵。不過Apple的這個看來係為了尊重使用者個資保護權利之政策，卻引來

113 雖然「規則（Regulation）」在歐盟法之位階為會員國一體適用，但是GDPR事實上仍給予會員國一定空間的評斷餘地（margin of appreciation），使會員國享有一定程度規範形成自由，使歐盟之監督不至於過度干預會員國主權。關於這個概念，詳參：翁燕菁，歐洲人權法院保障同性關係策略評析——彈性、局限及展望，中研院法學期刊，22期，頁77-141（2018年）。

114 European Commission, *Midday Press Briefing from 12/11/2018* (Nov. 12, 2018), <https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-163519>.

115 *User Privacy and Data Use*, APPLE, <https://developer.apple.com/app-store/user-privacy-and-data-use/> (last visited Apr. 24, 2021).

Facebook發出巨幅聲明予以反擊¹¹⁶，抨擊Apple之隱私政策調整一來未能明確而有效地說明第三方應用程式（尤其是Facebook與旗下應用程式）蒐集資料的目的；再者，這個個資保護作為也將限制許多作為使用者的小企業或個人使用者自媒體的廣告（言論傳播擴散）能力與效果。

此事件如參照我國司法院釋字第744號解釋認定（化妝品）廣告係利用傳播方法以宣傳商品效能，而具商業上意見表達之性質，則只要是該訊息內容非虛偽不實或不致生誤導作用，而係以合法交易為目的而有助於消費大眾作出經濟上之合理抉擇者，即「應受憲法第十一條言論自由之保障」，則顯見當社群平臺之言論流通出現法律規範爭議之時，個資保護、言論自由乃至於公平交易等不同之權利保護，具有發生衝突之可能。需注意者，這個案例之舉出並非在於說明具商業性質之媒體平臺個資蒐集是直接侵害言論自由的行為，而是於此可以觀察到在個資保護權利之行使後，可能間接地影響言論自由，也衍生出在法律規範上不同之權利保護出現競合之挑戰。

在這些利益衝突的實例中，通常第一個可能的處理方式，大都或多或少有著比例原則的影子¹¹⁷。不過比例原則的利益權衡方式有其固有之問題：當其在平衡權利或其所保障之利益時，在本質上保障其中一個正在競合中的基本權利，則另一個相對之權利必定相當程度地被弱化，然而，隱私概念的內涵卻往往基於個案與隱私權對科技之連結而發生變動，因此具有動態的「辯證性」，使得利益的權衡與權利的衝突競合問題如果僅依靠比例原則的衡量，可能造成恣意而徒具形式的判斷，失去客觀解決衝突問題的可能性¹¹⁸。

116 Dan Levy, *Speaking Up for Small Businesses*, META (Dec. 16, 2020), <https://about.fb.com/news/2020/12/speaking-up-for-small-businesses/>.

117 葉俊榮，探尋隱私權的空間意涵：大法官對基本權利的脈絡論證，中研院法學期刊，18期，頁11-14（2016年）。

118 葉俊榮（註117），頁11-22。

以歐洲的個資保護治理模式言，於歐盟不實訊息實踐準則第1條第6項與第7項中，也分別將二者權利保障基礎溯至歐洲人權公約第8條私生活權利保障¹¹⁹與第10條的表意自由權利保障。歐洲人權法院對於歐洲人權公約保障權利之限制案例中，在關於對權利之限制需「符合民主社會之必要」的詮釋問題上，或許可以發現法院的判決經常擺盪於具突破性的「動態式詮釋（dynamic interpretation）」或「進化式詮釋（evolutive interpretation）」與在文義解釋或是系統解釋下，較為保守的詮釋方式，給予會員國相對較寬鬆之判斷餘地，也就是較為「尊重」會員國各別社會文化傳統與法制之態樣。尤其是在關於歐洲人權公約第8條之判決中，法院也歸納認為在欠缺會員國之間存在的歐洲共識的情形下，則無論就系爭利益是否具重要性，或是保護該權利之手段而言，特別是當其引發難以評斷的道德或倫理問題時，會員國通常會被歐洲人權法院給予較寬廣之判斷餘地¹²⁰。換言之，其對於利益之衡平標準也通常傾向於拒絕採用一個可能會損及基本權利或會員國國內憲政秩序的衡平手段¹²¹。既然如此，究竟司法審查的標準又應為何？

（二）失序資訊之傳播過程的方式管制與審查標準

以個資保護作為管制不實訊息之方法也在關於言論意見傳播、溝通的治理上，表現出與言論自由管制在本質上之差異。基於本文在前已然說明以個資保護之模式作為管制不實訊息的治理模式與言

119 附帶一提，在歐洲人權公約制定時因為尚無個資保護明顯概念，因此沒有對應條文，不過歐洲人權法院於個資保護相關案件裁判時，均以該條私生活權利保障與（資訊）隱私權保障之規範，作為請求權基礎。

120 Daniel Rietiker, *From Prevention to Facilitation? Suicide in the Jurisprudence of the ECtHR in the Light of the Recent Haas v. Switzerland Judgment*, 25 HARV. HUM. RTS. J. 85, 116-17 (2012).

121 David Wright et al., *Precaution and Privacy Impact Assessment as Modes Towards Risk Governance*, in TOWARDS RESPONSIBLE RESEARCH AND INNOVATION IN THE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND SECURITY TECHNOLOGIES FIELDS 83, 93-94 (René von Schomberg ed., 2011).

論自由保護的關係乃是「補充／結合」關係，而非「競合／取代」之關係，故個資保護模式仍可以在既有的言論管制模式框架內展開，而不會推翻傳統觀點，也非一種獨立的管制方法。

在傳播投放過程上之管制，如果涉及言論內容之審查，則基於言論自由與個資保護在本質上之「結合」特性，本文認為由言論自由之管制與審查體系處理，而須面對相當高強度之司法審查挑戰；而當傳播投放過程上之管制及於對傳播平臺在資金、經營等面向之責任的管制時（例如，基於個資法施行細則第12條要求因為資訊安全而對組織有所要求的時候），即便屬於結構之管制，仍在關於言論自由管制審查之範圍，但學者則指出只要管制者能夠「證明具體結構管制手段和觀點多元化目標之間的必要連結關係」¹²²，便具有相對較佳的合憲可能¹²³。

而如果基於個資保護法理本質上的不同，將管制焦點放在言論／資訊的傳播投放過程，則由於對該等流動過程之治理政策工具在實際操作時，無論其內容與結構為何，僅在於「補充地」對於在傳播投放過程上不當地利用個資作為基礎而為管制加以處理。準此，就資訊隱私權保障之角度來說，必須使立法與執法者透過個人資料保護之程序性手段對於個人資料進行保障，方有可能以該程序達至「具有實質性價值內涵之要求」的目標¹²⁴。而學者也認為個資法可被定性為一種程序法性質，重點在於針對已然取得作用依據的資訊作為，「訂立程序上應遵守的各種規範」¹²⁵，例如個資保護法制中的「同意」相關概念，便應被理解為是一個程序性之機制，而非實質內容問題，以充分表彰權利主體（個資當事人）之個人意志的可

122 劉靜怡（註84），頁1155。

123 劉靜怡（註84），頁1149-1150，1154-1155。

124 邱文聰，從資訊自決與資訊隱私的概念區分——評「電腦處理個人資料保護法修正草案」的結構性問題，月旦法學雜誌，168期，頁179（2009年）。

125 邱文聰（註124），頁179。

能¹²⁶。在此必須說明反應權利主體意志的「同意」與關於言論內容自由、資訊隱私的實質性價值內涵之區別。從實質性基本權利內涵角度出發，學者認為在複雜的社會交錯事實中，必須依靠法規範之方式治理個體間的互動，但無論如何該等法規範之制定必須合乎於一定之基本原則而「間接適用」(indirect application)，此外，該等規範還必須同時顧及關於比例原則以及程序上權利主體同意(落實)之方法¹²⁷。具體而言，從資訊隱私權保障之角度來說，必須使立法與執法者透過個人資料保護之程序性手段對於個人資料進行保障，方有可能以該程序達至「具有實質性價值內涵之要求」的目標¹²⁸。再者，即便在資料主體並未經過程序上之同意，資訊仍可透過其他如公共利益之比例原則權衡等方式，而使得資訊流通。故而此處之管制型態，應認為係關於傳播過程之「程序上管制」，而基於個資保護法制的程序法性質，自也不應為關於言論內容之審查，則無損使用者在媒體平臺上自由發聲的完整性¹²⁹。

然而在實際操作上，精準投放的另一個與個資保護密切相關之問題在於該等基於特定演算法而精準投放政治性廣告與訊息之行為，係以機器自動化做成決策。不過毫無懸念地，在我國之個資法同樣在此部分付之闕如，仍屬真空之狀態而難謂有治理之基礎存在。

三、治理的建議

在前文中可以發現權利競合時往往難以期待具有通案性質且穩定的衡平方式，事實上關於言論保障下資訊與意見的自由流通，其

126 翁逸泓，開放全民電子健康資料加值應用之個資保護問題——以英國經驗為例，月旦法學雜誌，285期，頁159-160（2019年）。

127 ALAN GEWIRTH, REASON AND MORALITY 344 (1978).

128 邱文聰（註124），頁179。

129 於結構管制時，如未涉言論內容審查，則無損權利主體言論發生之完整。參：劉靜怡（註84），頁1152。另參：林子儀（註110），頁100-102。

中一個受矚目之處在於基於表意人對其現有資訊之認知，而為主體間的溝通連結，而資訊之自由流通事實上正是私生活權利¹³⁰與個資保護法律架構¹³¹之保障目的之一，故二者之間其實不必然地發生衝突，且在本質上是可能相互合作／結合的。質言之，對於私生活權利所需要條件之滿足，如果滿足了權利主體對於言論資訊流入與流出之私生活上自我控制能力，事實上對於言論自由之保障亦有助益。此際由於言論自由之保障之增進會使得權利主體間之信任提高，因此更樂於從事言論表意以完整其私生活之權利。因此，既然失序的言論市場當今的管制焦點漸漸地從言論稀缺之保護以及維護市場保有一定競爭性之傳統概念，演變為兼及於利用個資為投放來源的問題，則不妨讓以個資保護之模式引入成為失序治理之管制手段。對於此二基本權利避免競合之關鍵在於權利主體之間的相互信任，而建立起夥伴之關係¹³²。而這個信任之夥伴關係，本文認為可分別體現在關於透明原則與課責原則的法制與機制的建設之上。

130 ANDRÁS KOLTAY, *NEW MEDIA AND FREEDOM OF EXPRESSION: RETHINKING THE CONSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF THE PUBLIC SPHERE* 170 (2019).

131 例如我國個資法第1條：「為規範個人資料之蒐集、處理及利用，以避免人格權受侵害，並促進個人資料之合理利用，特制定本法。」；歐盟GDPR第1條第1項：“This Regulation lays down rules relating to the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and rules relating to the **free movement of personal data**.”（粗體強調為本文作者所加）。

132 關於該中概念之證成，學者認為從對於隱私之概念採較寬廣之解釋結果來看，保障私生活權利下的隱私權經常能夠包含了自決的權利，則不妨將言論自由中關於自我控制資訊流動的權利內涵包含在內。學者借用康德之論理認為應當將人／個體視作目的，則事實上無論是個資當事人或是資料持有人、管理人及利用人均應該理解：不應將彼此視作為從共同利益或是經由其各自之目的而得到的資訊利得，而應當將彼此視作是作為目的的伙伴，且此等伙伴之關係不但必須將對方視作目的本身，並應當將各方平等對待，一如對待己身，而非總將對方視作利益衝突之下的競爭對手。Deryck Beyleveld, *Data Protection and Genetics: Medical Research and the Public Good*, 18 KING’S L.J. 275, 275-89 (2007); Deryck Beyleveld, *Conceptualising Privacy in Relation to Medical Research Values*, in *FIRST DO NO HARM: LAW, ETHICS AND HEALTHCARE* 151, 156-59 (Sheila A. M. McLean ed., 2006).

在整體不實訊息治理架構上，本文認為具體之治理框架可區分為二個不同層次之議題而為雙支柱式（pillars）治理架構¹³³：其一為訊息內容本身之監理管制的問題；其二乃是訊息內容流動過程之監理管制問題，而在這個傳播途徑的層次上則除了言論管制外，本文認為可結合個資保護之管制。而本文認為個資模式的「治理」概念所包含的元素除了法律本身的建構以外，亦包括組織面之機制架構（institutional framework），尤其是在機制架構上應至少包括政府組織以及私部門對應機制的溝通協調，因此在流動過程的監理管制架構上，可分為法制上與機制上二個子面向架構。

首先關於法制的問題，基於本文前述論證在個資保護管制模式上最關鍵之處乃在於個資之蒐集階段，尤其必須注意包括合法性、課責與透明之個資保護原則，以強化個資當事人對其個資為何而蒐集，以及如何利用之控制可能，因此本文建議相關之治理規範至少需特別考量：

1. 資料蒐集之告知事項與同意方式：

雖然社群平臺大多已然在其隱私權政策聲明中提供了一些資訊，但該等告知在實務上仍必須踐行使當事人明確知悉個資蒐集目的之事項，並且尤其是在社群平臺將該等資料可能以任何方式轉予第三人時，必須避免在隱私權政策上的概括同意以踐行透明原則。事實上，依照我國2015年修法前個資法第20條第1項第6款以書面同意為特定目的外利用之事由，應注意該款所稱「書面同意」，乃指個資當事人經蒐集個資者

133 事實上多柱式管制或治理架構在我國並不陌生，例如同為通訊傳播領域之廣電三法與電信法的垂直式管制架構，電信之傳輸交換層有各種不同的技術規範，電信法涵蓋基礎網路層與營運層，廣播、電視則跨三層之垂直營運而彼此交疊形成治理體系。然，本文舉這個例子並不代表著在數位匯流時代下這種治理方式仍然是合適的，而個資保護與言論自由保護雙支柱式管制也有不同的補充結合方式。

明確告知特定目的外之其他利用目的、範圍及同意與否對其權益之影響後，依照個資法第7條第2項單獨所為之書面意思表示。

據此，實務上早已說明個資控制者（即此處向社群媒體蒐集個資之人）將告知書與同意書列於同一書面如而未明顯區隔，基於易造成個資當事人因為混淆而為概括同意，因此為避免其混淆，於執行個資法第8條之告知說明，與同法第19條第1項第5款、第20條第1項第6款需取得當事人書面同意而為特定目的外利用等情形時，最好能在不同書面，或至少另於同一書面之適當位置明顯區隔為之¹³⁴，並為妥適之個資保護影響評估，始符合合法性原則之期待。又，該等告知內容也須明確說明個資蒐集後之應用，尤其是關於人格剖析以及再為轉出之情狀。

而在2015年修法後即便因為放寬當事人「同意」之方式而不以書面同意為限，然而解釋上如果仍以書面為同意之方式，則仍應符合前述要求；如若不以書面方式為之，則需要以能擔保個資當事人不致混淆之方式，表達其個別之同意。

2. 強化轉出（利用）與接收（蒐集）個資者之責任：

ICO在劍橋分析案所提出的不實訊息檢討報告中對於社群平臺利用個資投放（政治）廣告，具體建議必須特別使該等媒體平臺遵守透明與課責原則¹³⁵。由於透明原則乃係行使各項個資權利在程序上之前提¹³⁶，因此為落實個資控管者課責，如果企圖利用個資為宣傳或散布資訊之人自個資中介者獲取

¹³⁴ 法務部102年12月5日法律決字第10200683890號及102年12月5日法律決字第10200683900號函參照。

¹³⁵ Information Commissioner's Office, *supra* note 79, at 42.

¹³⁶ GDPR前言第39點參照。

個資時，即必須為充分而盡責之調查，以確保合法取得個資，並且依前述之告知方式使個資當事人知道自己的個資將如何被以及將其傳遞給哪些組織利用¹³⁷。

如依照前揭考量之點作為上位原則，本文建議在具體關於訊息傳播面向的治理架構上，應就社群媒體平臺對於使用者個資從蒐集、處理、利用（共享）及刪除之完整資料生命週期為傳播途徑之全程治理，並使資料中介者之課責能落實。就此，我國在個資保護的規範上僅有一個具有基本法性質的個資法，在個別之領域如本文焦點的電子通訊傳播領域並無個資保護專法。本文認為事實上在這些特別領域中其實我國應有專法，而值此歐盟ePD（ePrivacy Directive）也即將提升為ePrivacy Regulation¹³⁸之際，本文也認為臺灣應盡快地在電子通傳領域訂立個資保護專法，並由個資保護獨立專責機關規管¹³⁹。在關於使用者資料之蒐集個資階段，本文前已說明治理的重點應特別在於個資所有生命週期上能彰顯使用者自主權的同意之程序，基於我國個資法並未明文直接地就「同意」之程序為揭示，解釋上該等同意必須足夠明確，因此本文建議至少需參照GDPR第7條關於同意的相關條件而為同意；又考量社群媒體平臺係透過通訊傳播之方式供消費者使用，因此在同意程序上應該是最能有資源與效率使得使用者在整體資料生命週期中進行諸多動態之同意選擇的¹⁴⁰，本文建議該等動態告知與同意方式可包括：

¹³⁷ European Data Protection Board, *supra* note 42, at 26-28; *See also* Information Commissioner's Office, *supra* note 79, at 30-31.

¹³⁸ Council of the European Union, *Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council: Concerning the Respect for Private Life and the Protection of Personal Data in Electronic Communications and Repealing Directive 2002/58/EC (Regulation on Privacy and Electronic Communications)*, Brussels, Feb.10, 2021 (OR. en), 6087/21, <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6087-2021-INIT/en/pdf> (last visited Apr. 24, 2021).

¹³⁹ 惟囿於篇幅，本文作者將另外為文分析制定專法之理據以及內涵。

¹⁴⁰ 在ICO的報告中指出Facebook在這方面雖然看起來好像提供了很多隱私設定的選項，但是整體看起來仍未能夠有效地讓使用者獲得資訊的告知。Information

1. 同意之內容除應簡單清楚以外，應以顯著而易於取得之方式為之；
2. 個資控管者不得以使用者同意在其裝置上存取資訊（即 cookies 或其他類似識別標籤技術）作為提供服務或功能之前提，且在涉及多個個資處理操作以實現多個目的時而能分別項目之狀況下不應包裹式捆綁同意¹⁴¹；
3. 承前，本文認為應給予使用者選擇願意被利用個資之剖析而投放之訊息類型，或至少例如被投放政治廣告時應特別通知個資當事人；
4. 就資料生命全週期在社群媒體平臺之處理，提高使用者同意之自主性，包括取得使用者之當事人同意或資料（再）利用及資料共享之補充告知、提供當事人撤回同意或選擇退出（opt-out）之選擇、將資料（再）利用與共享情形之資訊回饋通知予使用者。

除了強化社群平臺關於前述課責之外，如以使用者個資提供第三方投放訊息或廣告言論而為資料中介之服務，本文認為參照歐盟資料治理規則提案（Data Governance Act）¹⁴²中關於資料中介者責任之規定¹⁴³，應使其至少在個資保護面向上禁止目的外資料共享、後設資料僅准使用於發展原有資料共享服務、需對於資料持有者以及個資使用者保證其服務之近用具公平、透明與不歧視性之原則、持續並確保資料留存服務等，而定期向主管機關通報資料中介服務

Commissioner's Office, *supra* note 79, at 38.

¹⁴¹ GDPR, art. 7(4), 2016 O.J. (L 119) 1, 37.

¹⁴² Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on European data governance (Data Governance Act), COM (2020) 767 final (Nov. 25, 2020). 該提案旨在增加資料中介者（data intermediaries）之信任，並且藉強化資料共享機制以促進資料可用性。

¹⁴³ Articles 10-12 of the Proposal for Data Governance Act.

契約變更、個資侵害事件通報與因演算法變動之資料風險評估¹⁴⁴等情狀。

其次關於機制上之治理，本文認為就個資保護模式作為治理言，在我國個資法尚未規範，但是已於GDPR所規範的個資保護長（Data Protection Officer, DPO）制度在此或許能適度地強化規範效力與能量。依GDPR第37條第1項規定，符合下列三種情況之一之個資控管者，即應指派DPO：(1)公務機關處理個資、(2)核心業務即為處理個資，且該處理個資行為需對個資當事人，並進行大規模的常態性及系統性監控、以及(3)核心業務為大規模的處理特種個資或刑案個資。此時除公務機關以外，擁有一定影響程度之社群媒體平臺而企圖治理資訊，即符合前述第二個要件，應認為必須設置DPO，而課責原則在此正是個資保護長設立之原理。

詳言之，論者認為透過個資保護長之制度建立，不惟導入遵守各項個資保護基本原則之合法性與課責功能，更能使得該等基本原則更有效力（effective），以及有效率（efficiency）地¹⁴⁵被落實：與分散式兼管個資保護事項的傳統官僚行政制度不同，因為該等個資保護長有其專業且專責該等事項，因此能有效地運用其相配之資源與能力以達成其法律上保護個資當事人個資之責任，並且在該等個資保護責任與其他官僚庶務分立之情況下，有更大之機會避免利益衝突之發生。又，基於所有的公務機關均必須設有該職，則其覆蓋性更為全面，避免因為人力資源或預算微弱之偏遠行政機關發生個資事件時，無法處理而造成弱勢個資當事人受到權利侵害而難以有效救濟之問題。本文對此亦認為尤其是資訊保護長制度之建立，因為其理論上具有個資保護之專業能力，且在中央監管機關的統合與

¹⁴⁴ European Data Protection Board, *supra* note 42, at 30-31.

¹⁴⁵ Ana Maria Brezniceanu, *Data Protection Officer — A New Profession in Public Administration?*, 55 REVISTA DE ȘTIINȚE POLITICE. REVUE DES SCIENCES POLITIQUES 79, 80 (2017).

合作下較容易於交互作用形成緊密連結之有機體。最後，因為個資保護長係公務機關或企業常設職位，因此對於平時之包括個資教育宣導與定期稽核等職權功能，能較有效發揮，並能促進具有持續性特質之課責原則之實現。

而個資保護長之職權，依據GDPR之規範，至少包含了落實所有相關個資保護規範、監理特殊之個資處理事件，例如個資保護影響評估、辦理教育宣導與教育訓練以提升組織人員之個資保護意識與水準，以及最重要者與中央個資監理機關就個資保護事項合作等。為了滿足前述職務任務需求，其聯絡之方式亦應公開，同時，也正是為了滿足履行該等職務之需求，因此相應之硬體環境設備與資源等，亦應相對應地提供予個資保護長。並且，解釋上因為個資保護長落實以上所有職權均須透過對於該公務機關及企業所持有之個資的接近使用，因此原則上應賦予其近用單位保有的個資之權限。

綜言之，如果規範（例如個資法）上要求了個資保護長之設置，則在一定程度上能補足社會企業責任與自律機制此等在規範效力上較弱之點。但是在此必須注意的是，事實上個資保護長的設置與職權在觀察上，還必須與個資保護監管機關有一定之連動，也就是個資保護長依照GDPR之要求，其重要功能之一即在於與監管機關之合作，作為企業團體（與公務機關）之聯絡窗口，使得個資監管機關之作為能有效地下放至相關團體，方能更確保其功能。

不過如此一來，如果採用的是公私協力之治理模式，則私領域自律之建構仍有不足，在公部門之層面也需有相對應之銜接，而基於個資保護長與個資監管機關之連動性，便必須要面對關於個資監管機關本身的設置問題。需知，組織架構（institutional framework）之保障方式，向來是權利保障政策選項上重要的一環，這是因為一個（以上）具有具體職權與資源的組織，相對地有較強之能量將法規範所要保障之權利落實在實行面向上，並能夠擬定與監管政策，

學者對此更指出尤其是關於對社會企業責任的治理上，有力的組織架構更不可或缺¹⁴⁶。事實上，本文討論的不實訊息投放於社群平臺爭議，最顯著之國際案例便是劍橋分析案，英國於發生劍橋分析案的政治宣傳類型的不實訊息投遞事件時，其調查報告乃係由統整規管所有資訊行為之專責資訊委員做成並交國會。那麼，又為何需要此種獨立專責監管機關？在歐盟各會員國因歐盟整體法律架構上對於個人資料保護與資訊自決權作為基本權利保障態樣的嚴肅看待，因此其監督被視為「不可或缺的把關機制」¹⁴⁷，因此歐盟法院認為如果要限縮該等基本權利，甚至有發生與其他基本權利事項競合而容忍對該等基本權利侵害之情狀時，僅有於存在一個具常態性與持續性的獨立專責個資保護監察機關存在之前提下，方得允許¹⁴⁸。然反觀我國多頭馬車分散式地由目的事業主管機關兼管個資事項之規管方式以及人力與預算資源薄弱之狀態¹⁴⁹，則期待本文所論之以個資保護模式為不实訊息治理途徑，尤其是面對大量蒐集個資後的精準投放問題，似乎僅是緣木求魚的癡人夢話。

綜上，就訊息／言論內容之言論自由管制固不在本文討論範圍，以個資保護模式為不实訊息流動過程之監理管制之架構，在組織上本文建議應有一獨立之專責機關。不過目前在我國個資法尚未有修正而仍採由目的事業主管機關兼管個資事項的情況下，行政院基於希冀能達到確保國家資通安全、促進數位經濟發展及加速國家

¹⁴⁶ See Veselin Drašković & Andjelko Lojpur, *The Importance of the Institutional Framework in Regulating Corporate Social Responsibility*, 9 MONTENEGRIN J. ECON. 39, 39-46 (2013).

¹⁴⁷ 李寧修，警察存取預防性資料之職權與個人資料保護：以監視器之運作模式為例，臺大法學論叢，48卷2期，頁415（2019年）。

¹⁴⁸ Case C-158/07, *Jacqueline Förster v. Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep*, Judgment of the Court (Grand Chamber) of 18 November 2008.

¹⁴⁹ 關於這種個資保護監理模式之問題與建議，參：李寧修（註147），頁428-430；翁逸泓，資訊委員的時代角色——以GDPR及英國2018年資料保護法為中心，月旦法學雜誌，286期，頁40-42（2019年）。

數位轉型之目的規劃，而成立數位發展部，以作為推動數位發展的專責機關，則需要對於數位發展部是否適合作為個資保護模式對不實訊息管制之專責機關為考量。依照2022年1月19日制定公布之數位發展部組織法，數位發展部乃是**推動數位發展的專責機關**，將整合包括通訊、資訊、資安、網路與傳播五大領域，因此看起來在我國目前個資法主管機關附帶地兼管個資保護業務的規範下，非常地有可能成為社群媒體在利用個資作為投放訊息管制上之主管機關。然而同樣地，社群媒體本身在資料經濟層面具有發展效益，亦即為數位發展部本身的主要業務，則在發生個資管制問題時，似難期待主管機關放棄主要業務而就附隨義務之可能。再者，本文認為個資保護之職權與業務在數位發展中乃具有相當分量，則此次數位發展部並未規劃有個資保護之專責組織，因此在能量上與規範上均難以想像能具體地解決社群媒體利用個資投放不實訊息之問題。未來，一個獨立的個資保護專責機關，仍是可能的最佳解方。

伍、結論

本文肯認言論自由限制與審查之討論對於處理於社群媒體投放不實訊息相關爭議問題之重要性，然更主張以個人資料保護之概念出發，尤其針對處理個資作為精準投放之不實訊息為治理之芻議，提出論理上之建構與實際作為之建議。

就本文主要研究標的言，首先在辨識不實訊息問題面向上，本文認為在以資料為驅動之社群媒體資訊失序現況下，如果要尋得威脅民主社會之癥結，則與其聚焦在「惡」、「假」與「害」等構成要件爭點處理，毋寧應把焦點放在對於資訊傳述過程之有效辨識與積極對待。對此，本文認為雖然中性而作為技術應用來源的資料具有增益個人便利性之優點，然而該等應用對於基本權利與自由侵害之

法律風險，正是不實訊息投放造成民主焦慮之重大癥結。因此，詳細地審視在資訊傳遞過程中以大量個資剖析被投放者（即個資當事人）人格之行為，應有其必要性。

本文認為傳統言論管制不實訊息的處理策略中，除了可能出現關於涉及內容管制及其界限的典型爭議以外，也可能無法完整涵蓋的範圍。以個資保護作為管制不實訊息之方法，除了可以與言論自由之保障相互合作結合以外，也可以有效地補充處理關於牽涉資訊接收與獲取之利益，而與言論自由無法直接關聯之問題。在這裡需要特別提到的是，本文並不認為應當捨棄言論自由在不實訊息管制模式中所應扮演之角色，而是強調個資保護之管制方法在類型上與有效性上，可以與言論自由並行，強化並補充管制效果。據此，個資保護之概念不妨作為線上不實訊息投放之治理基礎之一。

在實踐面向上，本文對關於法制的問題，基於本文前述論證在個資保護管制模式上最關鍵之處乃在於個資之蒐集階段，尤其必須注意包括合法性、課責與透明之個資保護原則，以強化個資當事人對其個資為何而蒐集，以及如何利用之控制可能，因此本文建議相關之治理規範至少需特別考量個資在蒐集時的告知事項與同意方式，以及強化轉出（利用）與接收（蒐集）個資者之責任。最後，本文認為關於機制保護之問題，或許成立一個真正的獨立專責機關，才是目前臺灣能解決相關問題的起點。

參考文獻

1. 中文部分

- Harry G. Frankfurt著，南方朔譯（2006），放屁！：名利雙收的捷徑，臺北：商周。[Frankfurt, Harry G. 2005. *On Bullshit*. Princeton, NJ: Princeton University Press.]
- 王鵬翔、張永健（2019），論經濟分析在法學方法之運用，臺大法學論叢，48卷3期，頁791-871。
- 何吉森（2018），假新聞之監理與治理探討，傳播研究與實踐，8卷2期，頁1-41。
- 李寧修（2019），警察存取預防性資料之職權與個人資料保護：以監視器之運作模式為例，臺大法學論叢，48卷2期，頁391-437。
- 沈伯洋（2018），媒體意識轉換以及言論管制，月旦刑事法評論，9期，頁79-88。
- 林子儀（1988），言論自由之理論基礎，臺大法學論叢，18卷1期，頁227-275。
- （1992），新聞自由的意義及其理論基礎，臺大法學論叢，22卷1期，頁59-103。
- 邱文聰（2009），從資訊自決與資訊隱私的概念區分——評「電腦處理個人資料保護法修正草案」的結構性問題，月旦法學雜誌，168期，頁172-189。
- 翁清坤（2020），大數據對於個人資料保護之挑戰與因應之道，東吳法律學報，31卷3期，頁79-159。
- 翁逸泓（2018），科技人權——全民電子通訊監察與個人資料保護，臺灣民主季刊，15卷1期，頁1-43。
- （2019），開放全民電子健康資料加值應用之個資保護問

- 題——以英國經驗為例，月旦法學雜誌，285期，頁144-173。
- （2019），資訊委員的時代角色——以GDPR及英國2018年資料保護法為中心，月旦法學雜誌，286期，頁32-50。
- 翁燕菁（2018），歐洲人權法院保障同性關係策略評析——彈性、侷限及展望，中研院法學期刊，22期，頁77-141。
- （2019），言論的自由與責任：自歐洲人權法院近年爭議裁判反思，台灣法學雜誌，363期，頁5-12。
- 黃銘輝（2018），從言論自由的觀點初論網路假新聞的管制，收於：彭芸、葉志良編，「匯流、治理、通傳會」論文集，頁109-141，新北市：風雲論壇。
- （2019），假新聞、社群媒體與網路時代的言論自由，月旦法學雜誌，292期，頁5-29。
- 葉俊榮（2016），探尋隱私權的空間意涵：大法官對基本權利的脈絡論證，中研院法學期刊，18期，頁1-40。
- 劉定基（2017），大數據與物聯網時代的個人資料自主權，憲政時代，42卷3期，頁265-308。
- 劉靜怡（2011），媒體所有權、觀點多元化與言論自由保障：美國法制的觀察，臺大法學論叢，40卷3期，頁1089-1173。
- （2011），網路內容管制與言論自由——以網路中介者的角色為討論重心，月旦法學雜誌，192期，頁63-80。
- 鍾禎（2018），論國家對於假消息之管制模式及其規範分析——國際宣言與比較法的觀點，憲政時代，43卷3期，頁425-476。
- 蘇彥圖（2019），當代自由民主的焦慮，中研院訊，1694期，頁13-16。
- 蘇慧婕（2016），第三帝國陰影下的言論自由保障：論德國聯邦憲法法院在政治極右言論案件中的立場演變，臺大法學論叢，45卷2期，頁395-453。
- （2017），言論管制的中立性——美國雙軌理論和德國一般法律理論的言語行為觀點分析，收於：李建良編，憲法解釋之

理論與實務（九），頁201-269，臺北：中央研究院法律學研究所。

——（2019），假訊息管制與資訊揭露義務——以選罷法、公投法及其修正草案為中心，月旦法學雜誌，292期，頁42-59。

2. 外文部分

Bakshy, Eytan, Solomon Messing, and Lada A. Adamic. 2015. Exposure to Ideologically Diverse News and Opinion on Facebook. *Science* 348:1130-1132.

Benkler, Yochai, Robert Faris, and Hal Roberts. 2018. *Network Propaganda: Manipulation, Disinformation, and Radicalization in American Politics*. New York, NY: Oxford University Press.

Bernal, Paul. 2018. Fakebook: Why Facebook Makes the Fake News Problem Inevitable. *Northern Ireland Legal Quarterly* 69:513-530.

———. 2018. *The Internet, Warts and All: Free Speech, Privacy and Truth*. Cambridge: Cambridge University Press.

Beyleveld, Deryck. 2006. Conceptualising Privacy in Relation to Medical Research Values. Pp. 151-163 in *First Do No Harm: Law, Ethics and Healthcare*, edited by Sheila A. M. McLean. Aldershot: Ashgate.

———. 2007. Data Protection and Genetics: Medical Research and the Public Good. *King's Law Journal* 18:275-289.

Birkinshaw, Patrick J. 2020. Competition, Regulation, Public Service and the Market. In *European Public Law: The Achievement and the Brexit Challenge*. 3d ed. Alphen aan den Rijn: Kluwer.

Borgesius, Frederik J. Zuiderveen, Judith Möller, Sanne Kruikemeier, Ronan Ó Fathaigh, Kristina Irion, Tom Dobber, Balazs Bodo, and Claes de Vreese. 2018. Online Political Microtargeting: Promises and Threats for Democracy. *Utrecht Law Review* 14:82-96.

- Brezniceanu, Ana Maria. 2017. Data Protection Officer — A New Profession in Public Administration?. *Revista de Științe Politice. Revue des Sciences Politiques* 55:79-88.
- Dražković, Veselin, and Andjelko Lojpur. 2013. The Importance of the Institutional Framework in Regulating Corporate Social Responsibility. *Montenegrin Journal of Economics* 9:39-46.
- Frankfurt, Harry G. 2005. *On Bullshit*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Fukuyama, Francis. 2018. *Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment*. New York, NY: Farrar, Straus and Giroux.
- Georgieva, Ludmila, and Christopher Kuner. 2020. Article 9 Processing of Special Categories of Data. Pp. 365-384 in *The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A Commentary*, edited by Christopher Kuner, Lee A. Bygrave and Christopher Docksey. New York, NY: Oxford University Press.
- Gewirth, Alan. 1978. *Reason and Morality*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Ginsburg, Tom, and Aziz Z. Huq. 2018. *How to Save a Constitutional Democracy*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Habermas, Jürgen. 1990 (1983). *Moral Consciousness and Communicative Action*, translated by Christian Lenhardt and Shierry Weber Nicholsen. Cambridge, MA: MIT Press.
- . 1993 (1985). *Justification and Application: Remarks on Discourse Ethics*, translated by Claran P. Cronin. Cambridge, MA: MIT Press.
- . 2006. Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Enjoy an Epistemic Dimension? The Impact of Normative Theory on Empirical Research. *Communication Theory* 16:411-426.

- Helberger, Natali, Katharina Kleinen-von Königslöw, and Rob van der Noll. 2015. Regulating the New Information Intermediaries as Gatekeepers of Information Diversity. *Info* 17:50-71.
- King, Gary, Jennifer Pan, and Margaret E. Roberts. 2013. How Censorship in China Allows Government Criticism but Silences Collective Expression. *American Political Science Review* 107:326-343.
- . 2017. How the Chinese Government Fabricates Social Media Posts for Strategic Distraction, Not Engaged Argument. *American Political Science Review* 111:484-501.
- Koltay, András. 2019. *New Media and Freedom of Expression: Rethinking the Constitutional Foundations of the Public Sphere*. Oxford: Hart Publishing.
- Laidlaw, Emily B. 2015. *Regulating Speech in Cyberspace: Gatekeepers, Human Rights and Corporate Responsibility*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Levitsky, Steven, and Daniel Ziblatt. 2018. *How Democracies Die*. New York, NY: Crown.
- Longford, Graham, and Steve Patten. 2007. Democracy in the Age of the Internet. *University of New Brunswick Law Journal* 56:5-15.
- Matsumi, Hideyuki. 2018. Predictions and Privacy: Should There Be Rules about Using Personal Data to Forecast the Future?. *Cumberland Law Review* 48:149-210.
- Mill, John Stuart. 2008. *On Liberty: With Related Documents*, edited by Alan S. Kahan. Boston, MA: Bedford/St. Martins.
- Mounk, Yascha. 2018. *The People vs. Democracy: Why Our Freedom Is in Danger and How to Save It*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Pariser, Eli. 2011. *The Filter Bubble: How the New Personalized Web Is*

- Changing What We Read and How We Think*. London: Penguin Books.
- Pasquale, Frank. 2015. *The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Rietiker, Daniel. 2012. From Prevention to Facilitation? Suicide in the Jurisprudence of the ECtHR in the Light of the Recent *Haas v. Switzerland* Judgment. *Harvard Human Rights Journal* 25:85-126.
- Schmitt, Carl. 2008 (1928). *Constitutional Theory*, translated by Jeffrey Seitzer. Durham, NC: Duke University Press.
- Schrey, Joachim. 2017. General Conditions for Data Processing in Companies under the GDPR. Pp. 105-194 in *New European General Data Protection Regulation: A Practitioner's Guide*, edited by Daniel Rücker and Tobias Kugler. Oxford: Hart Publishing.
- Sunstein, Cass R. 2001. *Echo Chambers: Bush v. Gore, Impeachment, and Beyond*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- . 2007. *Republic.com 2.0*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- . 2017. *#Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Wright, David, Raphaël Gellert, Serge Gutwirth, and Michael Friedewald. 2011. Precaution and Privacy Impact Assessment as Modes Towards Risk Governance. Pp. 83-97 in *Towards Responsible Research and Innovation in the Information and Communication Technologies and Security Technologies Fields*, edited by René von Schomberg. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- Wu, Tim. 2018. Is the First Amendment Obsolete?. *Michigan Law Review* 117:547-581.

The Governance of Disinformation on Social Media:

Using the Personal Data Protection Model as an Option

*Wesley Yi-Hung Weng**

Abstract

This article explores the possible rationale and framework for the governance of disinformation through the use of personal data on social media. In the process of practicing democracy, Taiwan is threatened by internal and external disinformation disturbances either during or after the election. The attack of disinformation has not been slowed down by the end of the large-scale election, and its spread is on a cross-platforms basis. In addition to affecting the rights enshrined under the personal data protection law, it also drastically reduces the trust relationship between members of society.

This article uses relevant EU legislation, research, and practical strategies as frames of reference. The author believes that if we want to find the crux of threats to a democratic society, we should instead focus on the issues of “intention”, “fakeness”, and “harm”. The focus should also be placed on the effective identification and positive treatment of the information dissemination process, in particularly, the data collecting stage. After analysing the relationship between the personal data protection model as the entry point of disinformation control and balancing it with the protection of freedom of speech, this article believes that in the legal system, special attention should be paid to the accountability of the data controller and the data intermediary. Lastly, this article suggests that the independent data protection agency as an

* Associate Professor, College of Law, Shih Hsin University.

institutional framework is the starting point for Taiwan to solve aforementioned problems.

KEYWORDS: data protection, GDPR, disinformation, fake news, freedom of speech.